

分 类 号：_____
论文编号：2019020365

密级：公开

贵 州 大 学
2022 届硕士研究生学位论文

论我国生物识别信息的民法保护

学科专业：法律（法学）
研究方向：不区分研究方向
导 师：杜明强
研 究 生：郭景灏

中国 ▪ 贵州 ▪ 贵阳

2022 年 6 月

硕士学位论文答辩委员会名单

论我国生物识别信息的民法保护

答辩人：郭景灏

答辩委员会委员：

贵州大学 胡卫 职称：教授（主席）

贵州大学 刘沂江 职称：副教授

贵阳学院 陈静忠 职称：副教授

答辩秘书：罗青青 硕士

答辩时间：2022 年 5 月 24 日

答辩地点：贵州大学北校区逸夫楼 422 智慧教室

摘要

生物识别信息是个人信息的一类，其是生物识别技术的产物，由于生物识别信息与人身不可分离以及识别的准确性，其已经大规模应用于我国各种社会场景，除了被运用于疫情防控、国家反恐以及社会安全等涉及公共利益的场景，还被大规模应用于支付安全、设备网络账号锁控方式等涉及私人利益的场景，因此对生物识别信息的立法保护急需提上日程。随着我国《民法典》的出台，个人信息正式被视为民法所保护的一项利益，生物识别信息也被作为个人信息的一类纳入民法的保护中，而随着《个人信息保护法》的出台，生物识别信息的保护力度得到进一步的加强，但是在法律层级未明确生物识别信息，未设立专门的保护规范对生物识别信息采取区分保护的措施以及侵权救济困难等困境依然存在。因此本文通过四个部分的内容相应规范进行对比阐释，对我国生物识别信息的民法保护的完善提出见解。

利用人体生物特征作为识别身份的方式在我国有着悠久的历史，而随着生物识别技术的发展，生物识别信息的概念也在发展，如今生物识别信息是以人体生理和行为特征为识别对象通过技术处理生成的个人信息。生物识别信息作为一项民事利益本质上是人格利益，因为生物识别技术的大规模运用提升了生物识别信息遭受侵权的风险，以及其与一般个人信息和隐私权不同的特性，让他成为一项值得民法保护的利益。

我国生物识别信息的主要通过民法典人格权编中的个人信息规范、隐私权规范以及人格权禁止令制度、合同编规范和侵权责任编规范予以保护，通过对相关民事规范的对比分析，以及结合我国生物识别信息的司法实践纠纷，可以探知我国生物识别信息的民法保护仍存在着法律概念不明确、未区分保护生物识别信息以及侵权救济制度不完善的困境。

为了解决现行我国生物识别信息的民法保护之困境，对比了采取专门立法保护模式以及综合立法保护模式国家与地区关于生物识别信息保护的法律法规，从中可以发现无论是专门立法保护模式还是综合立法保护模式，会通过相应的法律法规对生物识别信息的概念以及范围作出明确规定，如果没有规定的会出台指引进行说明解释增进公民对法律的理解与适用。结合国外司法实践，美国法官对生物识别信息的范围采取体系解释目的解释的方法进行进一步确定，另外提出生物识别信息的损害结果应当具体，但具体性

标准的内涵不明，导致对损害的认定标准也存有争议，美国通常采用引入行为自身可诉性侵权制度或者引入信息损害概念降低对损害具体性的要求。

综上解决目前我国生物识别信息的民法保护困境，需要在法律层级上确定生物识别信息的概念；设立专门针对生物识别信息的民事法律规范，将生物识别信息的敏感性与私密性作为区分标准，引入区分保护原则对生物识别信息进行分类保护，对生物识别信息与其他信息隐私权以及生物识别信息类别之间进行区分保护。最后完善生物识别信息的侵权救济制度，需要引入无过错归责原则，针对泄露信息的行为进行规制，并引入行为自身可诉性侵权制度、转变传统损害观念引入风险损害，降低损害的确定性要求，并明确公益诉讼可使用惩罚性赔偿。

关键词：生物识别信息；民法保护；侵权责任；个人信息保护

ABSTRACT

Biometric information is a kind of personal information. It is the product of biometric technology. Due to the inseparability between biometric information and human body and the accuracy of identification, it has been widely used in various social scenes in China. In addition to being used in epidemic prevention and control, anti-terrorism security, social security and other scenes involving public interests, it has also been widely used in payment security Device network account locking and other scenes involving private interests, so the legislative protection of biometric information urgently needs to be put on the agenda. With the promulgation of China's civil code, personal information is officially regarded as an interest protected by the civil law, and biometric information is also included in the protection of the civil law as a category of personal information. With the promulgation of the personal information protection law, the protection of biometric information is further strengthened, but biometric information is not defined at the legal level, There is no special protection standard, the measures of differential protection for biometric information and the difficulties of tort relief still exist. Therefore, through four parts, this paper puts forward some opinions on the improvement of civil law protection of biometric information in China from the perspective of legislation.

Biometrics has a long history in my country as a way of identification. With the development of biometric technology, the concept of biometric information is also developing. Nowadays, biometric information is generated through technical processing based on the physiological and behavioral characteristics of the human body. Personal information. Biometric information as a civil interest is essentially a personality interest, because the large-scale use of biometric technology increases the risk of infringement of biometric information, and its characteristics different from general personal information and privacy rights make it a interests worthy of protection by civil law.

In order to solve the dilemma of the current civil law protection of biometric information in China, this paper compares the legal norms of biometric information protection in countries and regions adopting special legislative protection mode and comprehensive legislative protection mode, from which we can find that whether it is special legislative protection mode or comprehensive legislative protection mode, The concept and scope of biometric information will be clearly defined through corresponding laws and regulations. If there is no provision, guidelines will be issued for explanation to enhance citizens' understanding and application of the law. Combined with foreign judicial practice, American judges further determined the scope of biometric information by means of systematic interpretation and purpose interpretation. In addition, they proposed that the damage result of biometric information should be specific, but the connotation of specific standard is unclear, which leads to disputes on the identification standard of damage, The United States usually adopts the introduction of actionable tort system or the introduction of the concept of information damage to reduce the requirements for the certainty of damage.

In summary, to solve the current civil law protection dilemma of biometric information in China, we need to determine the concept of biometric information at the legal level, take the sensitivity and privacy of biometric information as the distinction standard, introduce the principle of differential protection to protect biometric information, and establish civil legal norms specifically for biometric information, distinguish and protect the privacy of biometric information from other information and the categories of biometric information. Finally, to improve the infringement relief system of biometric information, we need to introduce the principle of no fault imputation, regulate the behavior of divulging information, introduce the actionable infringement system of the behavior itself, change the traditional concept of damage, introduce risk damage, reduce the certainty requirements of damage, and clarify that punitive damages can be used in public interest litigation.

Key words: Biometric Information, Civil law protection, Tort liability,
Private information protection

目 录

引言.....	1
第一章 生物识别信息的基本界定.....	8
第一节 生物识别信息的内涵.....	8
一、生物识别信息的定义.....	8
二、生物识别信息的法律属性.....	10
第二节 生物识别信息的基本类别.....	15
一、生理特征识别信息.....	15
二、行为特征识别信息.....	18
第三节 生物识别信息民法保护的必要性分析.....	19
一、生物识别信息民法保护的现实必要性分析.....	19
二、生物识别信息的特殊必要性分析.....	23
第二章 我国生物识别信息的民事保护现状与困境.....	27
第一节 我国生物识别信息民事规范保护的现状.....	27
一、民法典人格权编对生物识别信息的保护.....	28
二、民法典合同编对生物识别信息的保护.....	33
三、民法典侵权责任编对生物识别信息的保护.....	34
第二节 我国生物识别信息民事司法保护现状.....	36
一、对“合法正当必要原则”的阐述.....	36
二、对“财产损害”的支持.....	38
三、对“精神损害”的谨慎.....	38
第三节 我国生物识别信息民事保护的困境.....	39
一、未明确生物识别信息的法律概念.....	40
二、未区分保护生物识别信息.....	42
三、生物识别信息的侵权救济制度存在疏漏.....	43
第三章 生物识别信息民事保护的比较法考察.....	46
第一节 生物识别信息专门保护模式.....	46
一、美国生物识别信息的民事立法保护.....	46
二、美国生物识别信息的民事司法保护.....	48
第二节 生物识别信息综合立法保护模式.....	52
一、列举生物识别信息的范围.....	52
二、规定生物识别信息类别与处理规则.....	53
三、规定生物识别信息的侵权救济措施.....	54
第三节 生物识别信息保护模式比较法评析.....	55
第四章 我国生物识别信息民法保护路径的完善.....	59
第一节 明确生物识别信息的法律概念.....	59
第二节 采用生物识别信息区分保护原则.....	61

一、个人敏感私密生物识别信息.....	63
二、个人敏感生物识别信息.....	63
第三节 完善生物识别信息的侵权救济制度.....	65
一、引入无过错责任归责原则.....	65
二、完善生物识别信息侵权损害赔偿制度.....	68
 结 语.....	 73
致 谢.....	74
参考文献.....	75

引言

一、研究背景与意义

90年代末,我国有学者开始对个人信息法律保护进行研究探讨,在这个阶段学界对个人信息的名称也没有达成统一的意见,有将其称为个人信息,有的学者将其称为个人资料,也有的学者受美国隐私权保护将个人信息称呼为个人隐私。二十一世纪初众多学者中对个人信息定义认识有所不同,有关联型、识别型以及隐私权型,但对个人信息的范围,他们有着相似的理解,即对个人信息的研究多关注于姓名、性别、年龄等个人身份信息。随着生物识别技术逐步成熟,其识别准确率大幅提高,应用场景趋向复杂化、多样化,大规模的应用推动了生物识别行业市场规模的增长。根据前瞻产业研究院发布的《2020年全球生物识别行业市场现状与发展趋势分析》,2019年全球生物特征识别技术市场规模约为200亿美元,而我国的生物识别市场在全球的市场占比虽然较低,但是我国作为世界上经济发展最快的国家,在可预见的未来,我国生物识别市场的规模会极大的增长。¹

生物识别技术在我国快速发展,生物识别技术以自然人的生理特征和行为特征为基准,对人的身份进行识别,生物识别技术的直接性让其得以在社会中进行大规模推广。生物识别技术的大规模应用也在社会中逐渐引起社会纠纷,人们逐渐对生物识别技术的大规模应用的正当性、必要性提出质疑,面部特征、指纹、虹膜等生物识别信息具有不可更改性,社会大众普遍担心生物识别信息收集存储的风险。在刑事案件中业已出现利用他人面部特征解锁支付限制窃取他人财物的情形,而在民事纠纷中,也出现消费者质疑经营者提供服务以收集生物识别信息为前置条件而提起侵权之诉的事件。

我国立法机关开始关注个人信息保护领域,针对个人信息的保护出台了许多有关的法律行政法规,但是关于生物识别信息的立法行为多偏重于行政立法,立法的侧重点也在于规定网络服务商的行政义务。我国《网络安全法》将生物识别信息纳入个人信息的定义范围,将生物识别信息纳入网络安全领域予以保护;《信息安全技术 个人信息安

1. 前瞻产业研究院:“2020全球生物识别行业市场现状与发展趋势分析 非接触式识别将得以大量应用”,前瞻网,<https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/201204-e37f7829.html>,2020年12月31日。

全规范》则将生物识别信息列为个人敏感信息，为信息处理者主体的行为提供实施标准。另外我国 2020 年颁布了民法典，规定了个人信息的定义，明确了生物识别信息属于个人信息，并在随后颁布的《个人信息保护法》对生物识别信息归类为敏感个人信息适用，但是《个人信息保护法》也没有正面回应生物识别信息的特殊性，对生物识别信息的特殊性出台相应的处理措施。

希望通过对生物识别信息的法理分析，通过对我国国内现行公法规范与私法规范的梳理与分析，并且借鉴域外生物识别信息的保护路径，明确生物识别信息的侵权责任归责原则，厘清生物识别信息的侵权行为，为《个人信息保护法》的立法路径以及生物识别信息的法律保护路径提供新的思路，平衡私权益与公共利益。

二、研究综述

（一）国内研究现状

国内对生物识别信息法律保护的研究较少，且极少关注生物识别信息民法保护问题。对生物识别信息的民法保护的探讨也是从隐私权、个人信息保护的角度或者从人脸识别信息、指纹识别信息等单一类别生物识别信息保护或者从对单一生物识别技术规制的角度进行探讨保护，极少以生物识别信息整体为视角。

1. 个人信息的保护路径研究

齐爱民教授 2005 年提出在我国对个人信息的保护应将其视作为一项民事权利予以保护。²王利明教授在 2012 年所发表的文章中认为对个人信息的控制本身就是一种私益，其权利构造与人格权一致属于绝对权，应该将个人信息定义为个人信息权予以保护。³范为在 2016 年提出以知情同意原则为核心的传统个人信息保护框架无法在大数据时代中起到应有的保护作用，反而加重了企业的负担，其通过对域外规范的分析提出应摒弃知情同意原则作为个人信息保护的框架，引入场景风险理论替代知情同意原则作为大数据时代下个人信息的保护手段。⁴针对范为提出的观点，田野副教授在 2018 年反对完全摒弃知情同意原则为个人信息保护的核心，他认为知情同意原则作为个人信息保护的基

2. 齐爱民：“论个人信息的法律保护”，《苏州大学学报》，2005 年第 2 期，第 34-35 页。

3. 王利明：“论个人信息权在人格权法中的地位”，《苏州大学学报》，2012 年第 6 期，第 70-71 页。

4. 范为：“大数据时代个人信息保护的路径重构”，《环球法律评论》，2016 年第 5 期，第 93-94 页。

石，在大数据时代下可以重构，场景风险理论可以与知情同意原则相结合，同意的内容应该根据信息种类、场景风险评估而予以区分。⁵高富平教授在 2019 年通过对个人信息可识别性的法律属性进行论述，认为自然人对个人信息应该享有支配性利益，认为个人信息的保护不应是权利保护的模式，而应该是法益保护模式，保护的是个人自治、身份以及平等利益，应该对个人信息保护和隐私保护规范进行区分。⁶程啸教授在 2019 年从利益视角以及救济视角两个方面对个人信息的法律属性进行论述，提出个人信息应是一种防御性的民事利益。⁷周汉华在 2020 年反对将个人信息纳入人格权保护范畴，认为个人信息权是一种新兴的公法权利。⁸

2. 人脸识别信息保护的研究

对人脸识别信息保护的研究在 2019 年至 2020 年迎来一种井喷的趋势，众多学者或通过对域外法律的介绍，或以人脸识别技术法律规制角度切入，从而寻找一种人脸识别信息的法律保护路径。

洪延青在 2019 年介绍了美国及欧盟关于人脸识别技术的法律规定，并提出人脸识别技术的规制应该从政府层面和行业自律两方面出发。⁹王禄生在 2019 年的发表文章中提出需要通过强化平台责任、明确作者声明义务以及提高公众素养三个方面为一体，建构一种事前与事中相结合的规制方式与法律共同规制深度伪造技术。¹⁰曹建峰也针对深度伪造技术法律规制提出看法，他在 2019 年提出应该从研发溯源鉴伪技术、加强大众教育、防止国外网络破坏活动以及设立分级分类管理制度这几各方面去规制深度伪造技术。¹¹朱巍教授在 2019 年认为人脸识别为可识别的个人信息属于民事权利，人脸识别信息内部可进行类别的有效区分。¹²朱芸阳副教授在 2019 年提出人脸可以按照社会属性进

5. 田野：“大数据时代知情同意原则的困境与出路 ——以生物资料库的个人信息保护为例”，《法制与社会发展》，2018 年第 6 期，第 112 页-114 页。

6. 高富平：“论个人信息保护的目的一——以个人信息保护法益区分为核心”，《法商研究》，2019 年第 1 期，第 98-99 页。

7. 程啸：“民法典编纂视野下的个人信息保护”，《中国法学》，2019 年第 4 期，第 36-37 页。

8. 周汉华：“个人信息保护的法律定位”，《法商研究》，2020 年第 3 期，第 53-54 页。

9. 洪延青：“人脸识别技术的法律规制研究初探”，《中国信息安全》，2019 年第 8 期，第 85-87 页。

10. 王禄生：“论‘深度伪造’智能技术的一体化规制——从‘杨幂换脸视频’谈起”，《东方法学》，<https://doi.org/10.19404/j.cnki.dffx.20191029.001>，2021 年 6 月 4 日，第 11-12 页。

11. 曹建峰：“深度伪造技术的法律挑战及应对”，《信息安全与通信保密》，2019 年第 10 期，第 38-39 页。

12. 朱巍：“人脸识别的法律性质认定”，《检察日报》，2019 年 11 月 6 日，第 7 版。

行内部区分,依照社会属性的强弱可将其法律内涵分为肖像权、个人信息及隐私权。¹³蒋洁在 2019 年提出面对人脸识别技术的侵权风险对人脸识别技术的规制强调构建同一的应用技术标准,以行业自治为手段,要求企业应积极履行相关的行为义务。¹⁴邢会强教授在 2020 年提出人脸识别技术存在风险大于收益的可能性,对人脸识别技术的规制应从构建责任底线、区分信息处理主体以及采取比一般个人信息更强的规制程度进行。¹⁵潘林青在 2020 年认为对面部特征信息的法律保护应该以《民法典》为基本法依据,将《个人信息保护法》作为严格保护的特别法依据。¹⁶2020 年赵精武博士提出人脸识别信息蕴含的可识别利益是民法应予以保护的民事利益,应该对知情同意原则的适用情形进行重新解释,并辅以技术标准的方式规范人脸识别信息的处理活动。¹⁷

3. 指纹识别信息的保护研究

指纹识别信息保护的研究主要从对公权力机关采集公民指纹信息的行为进行合宪性分析以及指纹信息隐私保护两方面进行研究分析,且多采用比较法考察的方法进行研究。

2011 年张建文博士通过对我国港澳台地区指纹资料法律规范的比较研究,提出应该推动出台个人资料保护法,规范指纹资料的隐私保护。¹⁸2012 姚岳绒提出公民对自身指纹信息享有信息自决权,国家强制采集指纹信息的行为不合宪。¹⁹2015 年张红教授在提出指纹信息属于个人敏感信息应当受到人格权、信息隐私权以及信息自决权的保护,这些权利同时具有公私属性,因此保护指纹信息要防止公权力的侵害,也要防止私主体的非法干涉。²⁰

4. 生物识别信息法律保护的研究

生物识别信息法律保护的研究相对于个人信息以及其他单一类别生物识别信息的

13. 朱芸阳:“「脸」的三重内涵及其法律规制”,虎嗅网,<https://www.huxiu.com/article/325308.html>,2021 年 11 月 8 日。

14. 蒋洁:“人脸识别技术应用的侵权风险与控制策略”,《图书与情报》,2019 年第 5 期,第 62-63 页。

15. 邢会强:“人脸识别的法律规制”,《比较法研究》,2020 年第 5 期,第 59-60 页。

16. 潘林青:“面部特征信息法律保护的技术诱因、理论基础及其规范构造”,《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》,2020 年第 6 期,第 83-84 页。

17. 赵精武:“《民法典》视野下人脸识别信息的权益归属与保护路径”,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》,2020 年第 5 期,第 26-28 页。

18. 张建文:“指纹资料隐私保护的基本思考——以港澳台地区指纹资料隐私保护为视角”,《兰州学刊》,2011 年第 3 期,第 120-123 页。

19. 姚岳绒:“身份证取得时强制性采集指纹行为的宪法分析”,《法学》,2012 年第 5 期,第 41 页。

20. 张红:“指纹隐私保护:公、私法二元维度”,《法学评论》,2015 年第 1 期,第 93 页。

法律保护研究来说，并不多。朱工宇在 2009 年提出生物识别技术能发展会引发隐私权侵权的风险，其比对美国法律以及判例，提出以宪法解释明确隐私权，民事上设立一般人格权，刑事上明确公权力机关收集生物信息应遵循合法比例原则并且确认侵犯个人信息可罚性，以及提出设立个人信息保护特别法。²¹刘越教授在 2016 年提出生物识别信息侵权的损害数额难以确定，应该对生物识别信息赋予财产权保护。²²付微明博士对生物识别信息法律保护进行了比较系统的研究，他在 2019 年和 2020 年分别发表了三篇文章，分别论述了生物识别信息的特殊性，因此其需要得到法律的保护；²³其次介绍率了域外生物识别信息的法律保护模式并提出在行政法上要设立独立的信息监管部门，刑法上设立“盗窃个人身份罪”或“侵害个人身份唯一标识罪”，民事上建立个人生物识别信息权利损害的民事诉讼救济机制；²⁴并且他提出完善民事诉讼救济机制应构建类诉讼制度，并且确立过错推定的归责原则，保护生物识别信息所有人。²⁵

（二）国外研究现状

欧盟与美国属于较早就着眼于从法律制度上对生物识别信息实施保护的政治体与国家，因此欧美学者们对于生物识别信息的法律保护的相关研究起步较早。在欧洲，学者 Jan Griepink 于 2006 年提出为了保护生物识别信息系统用户的隐私，防止他们遭到系统的侵害，应该对生物识别信息系统进行评析，随后又针对 1995 年欧盟颁布的《数据保护指令》提出信息处理除了应该遵循欧盟在《数据保护指令》中提出的比例原则、目的限制原则、准确性原则和储存限制原则外，还应该遵循遵循范围限定、明确目的、遵循比例、第三方监管等原则，后者得到了众多学者的认可，并认为是对欧盟制定的信息处理基本原则的补充。²⁶在 2007 年 Els Kindt 提出比例原则以及目的准确数据处理合乎目的是数据处理活动的基本原则。²⁷2013 年 Ioannis Iglezakis 从保护人权的角度出发，认

21. 朱工宇：“生物识别与隐私权保护之法律冲突及其协调”，《科技与法律》，2009 年第 6 期，第 26-28 页。

22. 刘越：“论生物识别信息的财产权保护”，《法商研究》，2016 年第 6 期，第 75 页。

23. 付微明：“大数据时代个人生物识别信息法律保护的重要意义”，《研究生法学》，2019 年第 4 期，第 135-137 页。

24. 付微明：“个人生物识别信息的法律保护模式与中国选择”，《华东政法大学学报》，2019 年第 6 期，第 84-86 页。

25. 付微明：“个人生物识别信息民事权利诉讼救济问题研究”，《法学杂志》，2020 年第 3 期，第 79-80 页。

26. Jan Griepink, "An Assessment Model for the Use of Biometrics," *Computer Law & Security Review*, vol. 22, no. 4, March 2006, pp. 316-319.

27. Els Kindt, "Biometric Applications and the Data Protection Legislation," *Datenschutz und Datensicherheit*, vol. 31, no. 3, March 2007, pp. 166-170.

为应该设立数据保护专员，对生物识别数据的使用进行审查和风险评估，以防止生物识别技术成为对个体监控的手段，以保护人权。²⁸随着伊利诺伊州率先进行对生物识别信息的保护立法，愈来愈多美国学者主张在美国各州推行，2017 年美国学者 Justin Kay 以及 Brendan McHugh 随即主张各州的生物识别信息保护立法应效仿伊利诺伊州。²⁹而另一位美国学者 Hannah Zimmerman 则认为美国联邦政府对生物识别信息保护的立法缺失，会造成信息泄露的风险，应当将其升格为美国宪法隐私保护层面予以保护。³⁰

三、研究方法

本文针对生物识别信息的民法保护问题进行相应的研究，采用的研究方法有以下几个：

（一）案例分析法

本文是关于生物识别信息的民法保护问题研究，生物识别信息作为个人信息的一类，纳入我国民法保护的时间较晚，我国相关的司法案例较少。但国外生物识别信息民法保护的研究起步较早，有不少的相关案例，本文将会通过对域外案例的检索引用，结合所研究焦点进行分析。

（二）文献分析法

本文的研究还在于大量的阅读，通过在中国知网、北大法宝、人大报刊复印资料等数据库查阅相关的文献资料，掌握生物识别信息的界定及其内涵。在阅读文献的基础上总结理论界对生物识别信息的进行深度剖析。这里的文献分析法还主要是在理论联系实际，文献联系案例基础上的文献分析法。

28. Ioannis Iglezakis, "EU Data Protection Legislation and Case Law with Regard to Biometric Applications," *Social Science Electronic Publishing*, vol. 5, no. 7, January 2013, pp.45-70.

29. Justin Kay and Brendan McHugh, "The Next Steps for Biometrics Legislation Across US," *LAW360*, May 2017.

30. Hannah Zimmerman, "The Data of You: Regulating Private Industry's Collection of Biometric Information," *Kansas Law Review*, vol. 66, February 2018, pp.637-643.

（三）比较分析法

域外对于生物识别信息相关法律保护的研究起步较早，域外也有相关的立法保护与司法案例，通过比较分析法，对比国外的立法现状、司法案例与理论研究现状，去寻找一条合适我国生物识别信息民法保护的民法保护的保护路径。

四、本文研究的创新之处

我国对生物识别信息民法保护的研究探讨多在民法典颁布之前，因此学者们多主张对生物识别信息的民法保护应采取赋权性的保护方法将生物识别信息视作一项独立的民事权利予以保护，而本文的创新之处在于本文不主张对生物识别信息实为一项独立的民事权利予以保护，而是在民事权益保护的视角下进行研究。

目前对生物识别信息的民法保护研究中，对生物识别信息的侵权责任规则研究较少，本文通过对现行公私法规范的梳理，分析出生物识别信息民法保护的困境，着重对生物识别信息的侵权法保护困境进行分析，针对生物识别信息的侵权责任提出完善的想法。

第一章 生物识别信息的基本界定

第一节 生物识别信息的内涵

一、生物识别信息的定义

在我国，将人体特征作为识别标识符有着长久的历史渊源，德国学者罗伯特·海因德尔认为中国首位提出通过指纹识别鉴别个人的是唐代作家贾公彦，海因德尔因此断言我国是世界上首个提出指纹识别的国家。³¹在我国古代，指纹作为一种鉴别个人的标识符，最早的应用场景并非仅发生在唐代，将指纹的识别运用在刑事断案的场景中，可追溯至战国晚期至秦朝这段时间，在出土的睡虎地秦墓竹简文物中，其《封诊式》有着详细的对指纹手印以及脚印的勘察记录。³²在民事领域，古人也多运用其指纹作为识别个体的工具，在唐宋时期已经出现古人通过指印或者掌印作为契约婚书休书等文书凭证。³³由此可见，古人的受教育普及程度不高，在当时的社会环境下，就出现了将自身人体特有的特征作为识别手段。因此生物识别在我国有着悠久的历史。

受制于古代的科技水平，当时都是将人体特征作为识别个体的手段，采用的方法是将人体特征，比如指印、手印、面容等，通过将其固定在实物上比如纸张、陶泥等实物载体，再通过肉眼进行对比，因此古代的生物识别往往更多是特指指纹识别、掌纹识别以及人脸识别。而随着科学技术的发展，人体特征并非只能通过实物载体进行复现，能作为识别标识符的人体特征越来越多，因此生物识别信息的内涵也得到了进一步的扩大和延申。我国民法典的颁布，明确了个人信息属于我国民法保护的民事利益，同时也采用了不完全列举式的描述方法，明确了生物识别信息属于个人信息的一种，同样受到我国民事法律的保护。³⁴但在民法典中，并未对生物识别信息的内涵作出一个明确的定义，

31. [德] 罗伯特·海因德尔：《世界指纹史》，刘持平、何海龙、王京译，北京：中国人民公安大学出版社，2008年版，第2页。

32. 徐同祥、李宇：“中国指纹技术的起源及其早期应用”，《江苏警官学院学报》，2012年3月，第116页。

33. 同上注。第117-118页。

34. 《民法典》第一千零三十四条第一款：个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

而我国其他的单行立法中也没有对生物识别信息作出定义，因此在立法上并没有对生物识别信息的内涵作出定义。现阶段我国虽然未对生物识别信息的内涵进行法律上的明确，但通过由国家标准化委员会颁布国家标准的方式，对生物识别信息的类别以及内涵进行明确。2020 年我国发布并实施了新的国家标准 GB/T 35273-2020《信息安全技术 个人信息安全规范》（以下简称《个人信息安全规范》），在《个人信息安全规范》的附录 B 表 B.1 中，列举出了生物识别信息的类别，规定生物识别信息的类别包括个人基因、指纹、掌纹、耳廓、虹膜、声纹、面部识别特征等。同时，在国家标准《信息安全技术 安全技术 生物特征识别信息的保护要求》（以下简称《生物特征识别信息的保护要求》）征求意见稿 3.1.4 条中，将生物特征识别数据等同于生物特征识别信息，将生物识别信息定义为：“生物特征样本、生物特性、生物特征模型、生物性质、原始描述数据的生物特征识别特征，或上述数据的聚合。”

根据《生物特征识别信息的保护要求》征求意见稿的相关定义，目前我国认为生物识别信息是生物特征数据化处理的信息。对比美国与欧盟对生物识别信息的定义，2008 年美国伊利诺伊州颁布了《生物识别信息隐私法案》（英文简称为 BIPA），在定义这一章节中，提出了生物识别标识符这一概念，伊利诺伊州认为无论如何获取、转换、存储或共享，只要是基于个人用于识别个人的生物识别标识符所构成的信息，即是生物识别信息；另外，《生物识别信息隐私法案》在提出生物标识符这一概念的同时，也规定了生物标识符的范围，该法案规定生物识别标识符的范围是虹膜、指纹、掌纹、声纹掌纹和面目特征，并且通过举反例的形式对生物识别信息的范围进行限缩，明确了不属于生物识别信息的种类，将用于医疗或科学目的的生物识别材料排除在生物识别信息得范围内。³⁵在欧盟，他们更愿意将生物识别信息称呼为生物特征识别数据，在他们颁布的《通用数据保护条例》（GDPR）第四条十四款规定了：“生物特征识别数据是指与自然人的躯体、生理以及行为特征相关的特定技术处理所产生的个人数据，比如面部图像和指纹数据。”通过对比欧盟、美国法律对生物识别信息的定义，可以发现在称呼上虽有不同的地方，比如美国伊利诺伊州采用的是“生物识别信息”的称呼，而欧盟则采用“生物特征识别数据”的称呼。至于我国，在已定以及拟定的国家标准中，都有采用“生物识别信息”和“生物特征识别数据”的称呼。虽然对生物识别信息的称呼、定义皆有所不同，但通过对比，我们发现美国与欧盟对生物识别信息的定义有着相似之处，无论

35. Illinois Compiled Statutes Chapter 740§14/10 (2008).

是《生物识别信息隐私法案》还是《通用数据保护条例》，首先都认为生物识别信息是以人体的生物和行为特征为识别的对象；其次，都明确了人体特征需经过技术上的处理，才可以成为法律意义上的生物识别信息，《生物识别信息隐私法案》强调生物识别标识符需经过相应的处理手段才可转变为生物识别信息，而《通用数据保护条例》则明确了生物识别信息是人体特征通过技术处理所产生的数据，因此生物识别信息本质上是生物识别技术的衍生物；最后生物识别信息的作用是用于对自然人身份上的识别。通过对比美国和欧盟对于生物识别信息定义的法律规定，以及结合我国《生物特征识别信息保护要求》征求意见稿的规定，私以为生物识别信息的内涵是为了识别自然人的身份，通过相应的生物识别技术，对自然人的身体特征进行信息化、数据化处理，使其能够自动识别自然人身份的信息。

二、生物识别信息的法律属性

生物识别信息的法律性质，学界上有着不同的看法，对其法律性质的争议主要存在人格权说以及财产权说两种学说。另外，对生物识别信息持人格权说的学者们，对生物识别信息是否应该成为独立的人格权也存有不同的观点，有的主张个人信息应当视为特别的人格权，将个人信息升格为信息自决权这一具体人格权，而生物识别信息作为个人信息的基本类别由信息自决权这一具体人格权予以保护；而有的则主张将生物识别信息纳入隐私权的规范体系中，通过隐私权的规范路径对生物识别信息予以保护。之所以对生物识别信息的民法保护路径发生分歧，原因在于研究路径的不一。欧盟的另行设立信息自决权的保护模式以及美国的“大隐私权”的保护模式，是我国学者的主要研究方向，正是因为研究方向的不同，导致了在对生物识别信息的民法保护路径上产生了分歧。

（一）人格权说

人格权的理论渊源部分来自于古罗马法，古罗马法中存在着市民权、自由权以及平等权等具体人格权的概念，体现了现代人格权的基本特征。随着时代的发展，学者们慢慢地从自由权、平等权等具体人格权中，提取公因式，逐渐发展出了一般人格权理论。1907年《瑞士民法典》中规定了一般人格权，是立法层面中首次明确了一般人格权的概念。在学理上，人格权的法律概念是由谁提出的则存有争议，有的学者认为人格权理论的奠基人是法学家海尔曼，有的学者认为是法国学者多内鲁斯。虽然学理上对人格权概

念的首次提出存有争议，但对一般人格权的首次全面的阐述皆认为是德国学者基尔克，其在《德国私法》一书中首次全面的论述了人格权的概念。³⁶人格权是主体依法享有的固定的、以人格利益为客体的、为维护主体的独立人格所不可或缺的权利。从人格权的概念中，我们可以知悉人格权，人格权是与人身不可分离的，生物识别信息作为以人的生物特征为识别对象，其本质上与人身是不可分离的，因此在主体上与人格权相契合。人格利益包括一般人格利益和个别人格利益，个别人格利益较为具体，譬如生命、健康、姓名等。一般人格利益主要是指公民的人身自由和人格尊严，人格利益大都体现为一定的精神利益，因此人格利益不具有有形的特征。生物识别信息人格权说的理论基础来源于信息自决权，信息自决权的概念来源于德国，其本意在于明确自然人对于自身的个人信息享有支配的权利，能自主决定是否允许他人对其个人信息进行收集处理，而信息自决权的产生基础来源于一般人格权。如前文所述，一般人格权的客体是一般人格利益，即人格尊严和人身自由，个人信息的可识别性，可以直接识别自然人的身份，体现了人格特征。一般人格权虽然具有补足具体人格权的作用，但一般人格权的内容缺乏明确性和确定性。在此背景下通过设立个人信息自决权，将个人信息纳入人格权的保护体系是便于自然人对自身个人信息的支配，更有助于对人格尊严的保护。³⁷因此生物识别信息作为个人信息的基本类别之一，对其的保护应该采用设立信息自决权这一具体人格权予以保护。

持隐私权说的学者们，认为个人信息是一种隐私利益，对个人信息可将其纳入隐私权的规范体系中。生物识别信息作为个人信息的子集，其与人体有着密切的联系，在一定程度表现为人体隐私，其权利属性在一定的程度下，与隐私权的权利属性也有所重合。隐私权为生物识别信息的权利属性这一学说来源于美国，前文中提到伊利诺伊州的《生物识别信息隐私法案》是美国境内首次颁布专门法案对生物识别信息予以法律上的保护，在《隐私法案》中明确生物识别信息的名称为生物识别隐私。隐私权这一法律概念的首次提出在美国，美国律师塞缪尔·沃伦和路易斯·布兰戴斯在《哈佛法学评论》发表了《论隐私权》，在学理上提出隐私权是人类人格和尊严的一部分，是一种权利。而在司法层面则是由法官科布在派威斯奇诉新英格兰生命保险案中首次确认隐私权。³⁸美国的隐私权侵权可划分为四种形式，分别是（1）无正当理由干涉私人领域及生活；（2）

36. 姚秋英：《人格权研究》，北京：中国政法大学出版社，2012年版，第1-3页。

37. 王利明，前注[3]，第69-71页。

38. 沈中、许文洁：《隐私权论兼析人格权》，上海：上海人民出版社，2010年版，第112-113页。

公开他人私人事实零他人困扰；（3）歪曲使用真实信息，造成错误印象；（4）为了自身利用未经许可适用他人肖像和信息。由美国隐私权的侵权形式，我们可以知悉，美国隐私权的内容范围宽广，涉及到的内容除了大陆法系狭义的隐私权外，还包括大陆法系一些具体人格权的内容，譬如姓名权，肖像权。因此美国法律体系下的隐私权，在一定程度上发挥着大陆法系一般人格权的作用，而生物识别信息作为个人信息的一种，在美国将其视为信息隐私权予以保护。因此持隐私权说的学者们受到美国隐私权理论的影响，主张生物识别信息的法律属性为隐私权。

（二）财产权说

无论是具体人格权说还是隐私权说，其重点皆是关注生物识别信息的人格利益属性。财产权说的提出，并非是为了否认生物识别信息的人格属性，而是在认可了生物识别信息的人格权属性前提下，对生物识别信息是否具有财产权属性进行讨论。传统民法理论认为财产权与人格权泾渭分明，一个权利不可能既是财产权或者是人格权。而持财产权说的学者们则对此持有着不同看法，刘越教授认为对生物识别信息财产权益的认可并不等同于对人格权属性的否认，个人信息的财产价值是以隐私的道德价值为基础的，生物识别信息采用财产权的民法保护路径可使生物识别信息所有人拥有控制、占有、转让等权利，保护的力度远大于隐私权的保护方法；³⁹刘德良教授认为承认个人信息的财产权，有助于解决传统人格权理论中，人格权受侵害无法请求财产赔偿以及自然人死亡后个人信息利用的问题；⁴⁰邢会强教授则认为生物识别信息作为个人信息的一部分可以划分为个人基本信息，个人基本信息能够单独或相互参照从而很容易地识别到特定个人，关乎其人格尊严与人格自由，因此具有人格利益。但是，由于其具有商业价值，因此具有财产利益，所以邢会强教授认为生物识别信息既有人格权的内容，也有财产权的内容。⁴¹财产权相对于人格权是一项积极的权利，在财产权说的视阈下，认可生物识别信息的财产权属性，能够赋予个人生物识别信息主体占用、转移、共享、利用和收益等权利。可权利范围远大于人格权，更有利于保护生物识别信息。

（三）人格利益说

39. 刘越，前注[22]，第80页。

40. 刘德良：“个人信息保护立法应明确人格权和财产权属性”，《中国信息安全》，2015年第5期，第94页。

41. 邢会强：“大数据交易背景下个人信息财产权的分配与实现机制”，《法学评论》，2019年第6期，第101页。

无论是人格权说还是财产权说,无论是具体人格权说还是隐私权说都拥有一个共同点,即认可生物识别信息是应当受到法律保护的一项民事利益。笔者认为生物识别信息的法律属性以人格利益说更为合理。诚然生物识别技术的大规模应用带来的后果是生物识别信息所有人会将其所有的生物识别信息通过生物识别技术转移至信息处理者所控制,信息企业进行相应的资本投入和人为干预对个人信息进行加工处理,使其实现了商业宣传推广与财产增量;再者,个人信息财产权的个人信息财产权的实质在于加强个人对其个人信息的控制,以专有性支配权排除他人非法干预与侵扰;⁴²并且生物识别信息多表现为生物识别数据,根据我国《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款的规定的规定,转移、收购、代为销售非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据达到一定数额的,可以认定为隐瞒犯罪所得,⁴³从该条款可以看出最高法最高检将数据视为虚拟财产,该解释虽然仅针对计算机系统数据,但生物识别信息的重要表现形式之一即为计算机系统数据,因此财产权说的学者们多从以上三个方向去论述生物识别信息的财产权。笔者认为生物识别信息本身不具有财产权的属性,其在社会应用的过程中呈现的财产利益是人格权商业化利用的结果,具有财产价值的并不是生物识别信息自身,而是生物识别信息的载体即数据。生物识别信息的客体是自然人的利益,生物识别信息的产生并非是人人为的创造过程,生物识别信息虽然通过生物识别技术对自然人的生物特征进行识别而产生,但这并非是人人为的创造过程,而是一种对人的生物特征以及行为的记录。生物识别信息是独立于个人之外,以非物质形式为存在形式的客观存在,并对特定的主体有着联系性和确定性的作用,只有确保生物识别信息与主体的一致,才能保护主体的人格尊严与人格自由。综上,“个人信息在本质上是关涉人的信息,是主观的‘人之为人’、‘人之行为’的客观映射,是人的利益通过可感知载体予以反映的结果。”⁴⁴因此人格利益是生物识别信息固有的法律属性。个人信息的商业化利用是不可避免的趋势,生物识别信息作个人信息的基本类别,同样也不可避免着商业化利用,但商业化利用并不意

42. 杨惟钦:“价值维度中的个人信息权属模式考察——以利益属性分析切入”,《法学评论》,2016年第4期,第66-75页。

43. 《最高人民法院 最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第七条第一款:明知是非法获取计算机信息系统数据犯罪所获取的数据、非法控制计算机信息系统犯罪所获取的计算机信息系统控制权,而予以转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,违法所得五千元以上的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。

44. 郭如愿:“大数据时代个人信息商业利用路径研究——基于个人信息财产权的理论检视”,《科技与法律》,2020年第5期,第78-80页。

味着应认可其财产权属性，前文简要述说了财产权说的理论依据与现实基础，但财产权说的理论仍有不足，生物识别信息赋予财产权的属性，的确能加强所有人对其的支配控制，个人可以依据其意志决定自身生物识别信息的归属，让自然人能获得生物识别信息的财产权益的同时，也能更好地保护其人格权益，但在网络社会时代，自然人对其自身的生物识别信息的支配掌控能力是不足的，信息处理主体能通过网络手段，私密地窃取自然人的生物识别信息，比如美国 FaceBook 被爆出通过技术手段，未经用户允许，自动截取识别用户发布在平台照片中的面部特征，生成个人标签并纳入 FaceBook 的数据库中。⁴⁵因此个体在面对以公司为单位的信息处理者时，对其生物识别信息并不享有完全的支配能力。并且生物识别信息能精准的识别自然人，基因信息、声纹、面部特征以及步态特征等生物识别信息能反应自然人健康状况，能形成相对应的用户画像，认可生物识别信息具有财产权属性，会导致信息处理者在利益的驱动下大规模出售生物识别信息，提高了对人格权益侵权的风险。因此笔者认为生物识别信息不具有财产权益的法律属性，人格权益是固有的法律属性，因人格权益的商业化利用，致使生物识别信息的载体呈现出财产权益。

除此之外笔者还认为，在我国现行的法律体系下，生物识别信息只能视为一项民事利益，而不能将其视为一项独立的具体人格权。在民法典中，个人信息与隐私权合并为同一章，被设置在人格权编中，民法典第一千零三十四条第一款明确规定了个人信息受法律保护，并在第二款中明确了个人信息的范围，生物识别信息属于个人信息的一类。⁴⁶从民事立法上认可了生物识别信息的人格权益的法律属性。但是从立法语义上，民法典并没有采用生物识别信息权这一称谓，也没有采用个人信息权或者信息自决权的称谓。人格权是绝对权，根据人格权法定原则，所有的人格权都应该通过法律对其予以确定认可，这是由于其绝对权的性质决定的，绝对权具有对抗一切权利人的效力，如果不经法律的确定，会对他人合理行为自由构成不当的限制。⁴⁷利益经过法律的确定当然会上升为权利，但这是需要一个发展的过程，“隐私”由受法律保护的利益上升为现今的“隐私权”也是经历了一个过程，因此从立法语义上生物识别信息并不能算一项独立

45. 牛谷月：“Facebook 因侵犯隐私向 160 万用户赔偿 6.5 亿美元 专家：人脸识别边界划分要靠法律”，央广网，http://finance.cnr.cn/2014jingji/djbd/20210304/t20210304_525427264.shtml，2021 年 3 月 4 日。

46. 《民法典》第一千零三十四条第一第二款：自然人的个人信息受法律保护。个人信息是以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人的各种信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

47. 程啸：《侵权责任法（第三版）》，北京：法律出版社，2021 年版，第 143 页。

的人格权。从生物识别信息的性质上看，现阶段其并不适合作为一项独立的人格权，人是社会性的动物，在社会交往活动中，人与人之间是通过个人信息相互识别，生物识别信息是对自然人生理特征行为特征的记录，其作用是对自然人的身份识别，可识别性是其核心，而交流是得以识别的前提。程啸教授也认为自然人不能对其个人信息包括生物识别信息进行排他的与独占的支配，因此他主张将个人信息即也包括个人信息视为自然人的一种防御性的民事利益给予保护。⁴⁸综上所述，在现行的民法体系上，生物识别信息并非一项独立的人格权，而其应是民法所应该保护的民事利益。

第二节 生物识别信息的基本类别

我国《个人信息安全规范》列出了生物识别信息的种类，包括个人基因、指纹、掌纹、耳廓、虹膜、声纹、面部识别特征等，以上的种类是人体的生物特征，通过技术手段处理而形成的生物识别信息，而根据《生物特征识别信息的保护要求》（征求意见稿）第 3.1.3 条，个体的生物特征可分为个体生理特征以及行为特征。综上，生物特征是个体固有的生理上或者行为上的特征，生物识别信息作为生物特征的数据集合信息，可划分为生理特征识别信息以及行为特征识别信息。

一、生理特征识别信息

生理特征是个体固有的生物特征，是与生俱来的。生理特征识别信息是直接采集人体的固有的生理特征，通过技术处理而形成的数据或信息，固定形式后具有稳定性高的特点。⁴⁹指纹、面部特征、虹膜以及指静脉等皆是个体固有的生理特征，因此指纹识别信息、人脸识别信息以及虹膜识别信息属于生理特征识别信息之一。

（一）指纹识别信息

每个人体的指纹是独一无二的，即使是同卵双胞胎也可能因为环境的差异导致他们的指纹相似却也有差别，这就导致了指纹识别信息具有唯一性。而且指纹是永久不变的，不会随着年岁的增长而有巨大的改变，在手指不遭受外来物理性损伤的情况下，指纹的

48. 程啸，前注[7]，第 36-37 页。

49. 郑方、艾斯卡尔·肉孜、王仁宇等：“生物特征识别技术综述”，《信息安全研究》，2016 年第 1 期，第 13 页。

纹路形状并不会发生太大的改变，因此指纹识别信息具有永久性的特征。不同的应用领域的指纹识别技术有着不一样的技术手段，但总的来说，生物识别技术的应用是为了对自然人身份的识别，因此即使不同应用领域的指纹识别技术之间存在差异化，但各项技术的内部验证构造，总体来说可以划分为三个阶段，图像采集、特征提取以及匹配识别。

⁵⁰通过设立各种物理传感器比如光学传感器等，对自然人的指纹进行采集，通过对指纹凹凸生成指纹图像数据，指纹识别系统在对数据图像进行特征采集分析，从全局或局部采取特征，从而收录进指纹识别的数据库，通过对比指纹所有人的指纹以及数据库的指纹特征，达到对自然人身份的识别。⁵¹因为指纹识别信息的技术性以及便捷性，所以指纹识别信息是社会生活中最普遍的生物识别信息之一。

（二）人脸识别信息

人脸识别信息是人脸识别技术的产物，现阶段运用最多的人脸识别技术共有两种分别是面部特征识别技术以及深度伪造技术，两种生物识别技术皆是需要对自然人的面部特征进行采集，但两种技术的侧重点皆有所不同。面部特征识别技术，是通过设立摄像装置，进行对自然人的面部特征图像采集或者视频采集，通过检测技术检测图像视频中是否存在人脸，如果存在人脸则收集人脸大小和各个面部器官的位置信息，并将其纳入数据库内，从而达到对比识别的作用。⁵²而深度伪造技术（DeepFake）俗称“换脸”，该项技术可将自然人的面部特征替换至视频之上，其面部也会随着视频的推进而实现相应的表情。深度伪造技术与面部特征识别技术一样，会对自然人的面部特征进行采集，并生成图像。但深度伪造技术不同之处在于，其引入了“对抗生成网络”的模型，“对抗生成网络”共有两组神经网络共同运作，一组神经网络利用互联网视频数据作为其源数据，通过源数据与所采集的自然人面部图像结合，生成新的伪造的图像；而第二组神经网络则需要对生成的伪造图像进行验证，目的在于让生成的伪造图像趋近于真实图像，通过对伪造图像的一次次验证，使其趋近于真实图像，从而让伪造的图像替代源数据所提供的真实图像。总的来说，深度伪造技术就是“通过深度学习的算法，去识别目标人物（比如明星、政治家）不同角度、姿态与表情的照片，然后不断训练从而自动生成

50. 孙哲男、赫然、王亮等：“生物特征识别学科发展报告”，《中国图像图形学报》，2021年第6期，第1267页。

51. 祝恩、殷建平、张国敏等：《自动指纹识别技术》，长沙：国防科技大学出版社，2006年版，第6页。

52. 郑方、艾斯卡尔·肉孜、王仁宇等，前注[49]，第16页。

伪造的图片，并将其覆盖到原有视频人物的脸部，形成‘换脸视频’。”⁵³因此相对面部识别特征技术，深度伪造技术除了强调“识别”的功能，也强调对人脸的处理。无论是面部特征识别技术，还是深度伪造技术，其对自然人的面部特征的采集较为容易，面部特征识别技术可以通过在公共场合设置摄像机器，即可获得自然人的面部特征识别信息，而深度伪造技术除了可通过设置摄像采集自然人的面部特征，还可通过互联网进行采集，如今的互联网含有大量的视频数据与图像数据，深度伪造技术可通过对互联网数据的抓取而获得自然人的面部特征。从这两种技术中，我们可以探知，人脸识别信息与其他生物识别信息相比，其优势是采集的可远距离和非接触性，即无需通过物理性的接触行为，即可采集自然人的人脸识别信息。人脸识别信息的易采集性，让信息处理者备受青睐，同时远距离采集的优势，也让信息处理者可以秘密地未经信息所有人的同意，采集自然人的人脸识别信息，加大了信息泄露的风险。

（三）虹膜识别信息

人体的眼白与瞳孔之间的一圈环状薄膜就是虹膜，虹膜识别就是利用计算机、光学传感器和模式识别技术，通过对虹膜进行自动采集生成图像并且对图像进行对比验证，以实现自然人的身份识别及验证。虹膜识别信息具有唯一性、稳定性以及高安全性等特点。虹膜的外观具有不规则的褶皱、条纹以及斑点，每个自然人的虹膜其褶皱、条纹以及斑点的分布都是不一样的，因此虹膜识别信息具有唯一性；虹膜在自然人一岁之后，其外观不会有太大的变化，因此虹膜识别信息具有稳定性的特点；虹膜识别信息与面部识别信息一样，具有采集手段的非接触性，但是与人脸识别信息相比，因为虹膜的形状较小，凭借肉眼无法观察虹膜的褶皱、条纹以及斑点的分布排列情况，因此即使采集手段具有非接触性，对虹膜识别信息的采集仍需信息所有人的配合，因此虹膜识别信息具有高安全性的特点。利用虹膜识别信息识别自然人身份需经过三个阶段，分别是虹膜图像采集、虹膜图像预处理以及虹膜特征抽取对比。⁵⁴通过摄影设备获取，整个眼球图像后，则需要通过对该眼球图像进行切割划分，将眼球中虹膜那一部分从原图像截取分割，然后将所截取的虹膜图像进行特征抽取以及对比，从而达到实现识别自然人身份的作用。

53. 王禄生，前注[10]，第2页。

54. 孙哲男、赫然、王亮等，前注[50]，第1263页。

二、行为特征识别信息

生物特征识别信息的另一大类就是行为特征识别信息，行为特征识别信息与生理特征识别信息不同，行为特征识别信息是以自然人的行为过程为识别对象。但行为特征与生理特征之间虽然识别对象不同，但两者之间也存在着紧密的关联，自然人的行为特征会受到其生理特征的影响，比如自然人的声带构造决定了其声纹。⁵⁵

（一）声纹识别信息

声纹识别是指根据语音信号中能够表示自然人的声纹特征，利用计算机以及各种信息识别技术，自动确认或分辨说话人身份的生物特征识别技术，声纹作为语音信号中的一种信息，是对语音信号中所蕴含的能表征说话人身份的语音特征以及基于这些特征所建立的语音模型的总称。⁵⁶声音的产生依赖于发声器官，通过声带的振动发出声源，并通过鼻腔口腔等器官调整声调。每个人的器官构造不一样，常用的发声腔调也有所不同，这就决定了每个人的声纹都是不一样的，即使模仿他人的声线，从听感上并无差异，但由于发声器官构造的不同，可借助技术手段对声纹进行分析从而达到辨别自然人身份的目的。声纹识别分为声纹辨认和声纹确认，无论是声纹辨认还是声纹确认，声纹识别的技术都可总结为三个阶段，声纹采集、声纹训练以及识别。首先通过设置录音设备，采集自然人的语音讯息并从中提取声纹特征，其次对所采集的自然人声纹特征进行多次训练形成相对应的语音者模型，并将所有语音者的模型集合而成一个用于对比验证的数据库，最后就是对自然人进行识别认证，系统通过对待识别语音进行声纹特征提取，并将提取的特征与数据库进行对比，根据相对应的相似性识别自然人身份。综上，声纹识别信息作为一种生物识别信息，其拥有独特性、非接触性以及采集方便性等特点。

（二）步态识别信息

步态识别信息相对于其他生物识别信息，应用的时间不长，步态识别技术属于新兴的生物识别技术。由于行人在肌肉力量、肌腱和骨骼长度、骨骼密度、重心等方面有一定的差异，这就导致了行为人的行走姿势各不相同，因此步态也可以作为识别自然人身

55. 郑方、艾斯卡尔·肉孜、王仁宇等，前注[49]，第13页。

56. 刘乐、陈伟、张济国等：“声纹识别：一种无需接触、不惧遮挡的身份认证方式”，《中国安全防范技术与应用》，2020年第1期，第33-34页。

份的一种手段。步态识别是指利用图像和视频序列，通过建立模型提取目标人物步态轮廓特征，从而对目标人物进行身份识别。⁵⁷步态识别的技术原理是可分为四个阶段，分别是步态采集、步态分割、特征提取以及识别对比。通过摄像装置，采集自然人的步态数据，其后从采集到的视频序列图像对人体的步态轮廓进行分割，再者对所分割的步态轮廓进行特征提取，并将提取到的步态特征构建一个相应的数据库，最后通过采集到的步态特征与数据库内所含有的步态特征进行比对，从而识别自然人的身份。⁵⁸

第三节 生物识别信息民法保护的必要性分析

生物识别信息是生物识别技术发展的产物，生物识别技术的大规模应用方便了大众，提高了人民的生活质量的同时，也带来了许多担忧与纠纷。有学者担心生物识别技术大规模应用，会让生物识别信息与其他个人数据相结合形成的用户画像，用户画像会成为新时代公民的身份表征，会导致算法歧视，有违平等。⁵⁹生物识别技术的应用让人们更多考量的是对技术本身的规制，希冀通过公法领域对滥用生物识别技术的行为进行规制。但生物识别技术所导致的纠纷不仅仅存在于公主体与私主体之间，还往往会存在与私主体之间。无论纠纷的表现形式如何，其侵犯的核心仍是私益。因此单纯凭借公法对生物识别技术进行调整规制，并不能完全起到保护公民合法权益之效。生物识别信息应该以民法保护为主要的保护路径。

一、生物识别信息民法保护的现实必要性分析

生物识别信息是生物识别技术的产物，前文中对基本类别的生物识别信息进行了一个基本的罗列，由于生物识别技术的大规模应用，所以生物识别信息成为个人信息中较为常见的个人生物识别信息。生物识别信息作为一项值得民法保护的民事利益，其存在着现实必要性，即生物识别技术的大规模应用不同的社会场景中，虽然提升了人民的生活便利，但也给自然人带来了相对应的侵权风险。

（一）生物识别技术及其应用场景

57. 孙哲男、赫然、王亮等，前注[50]，第1276页。

58. 朱应钊、李嫚：“步态识别现状及发展趋势”，《电信科学》，2020年第8期，第131-132页。

59. 郭锐：《人工智能的伦理和治理》，北京：法律出版社，2020年版，第136页。

生物识别技术是通过计算机与光学、传感器等技术,针对自然人的生理特征与行为特征进行采集对比,从而对自然人身份进行识别的一项技术。其是一项总称,针对所识别的特征不同,生物识别技术也有所不同,譬如针对面部特征的生物识别技术为人脸识别技术和深度伪造技术,针对指纹特征的指纹识别技术,针对声音的声纹识别技术等等。针对不同的生物识别技术,本文列举了面部识别特征技术、指纹特征识别技术、虹膜识别技术、声纹识别技术以及步态特征识别技术五项不同的生物识别技术,从它们便利程度、采集是否发生物理性接触、普及程度、盗取的难度、以及识别对象的准确性五个方面进行比较(见表一)。通过表一我们可以发现在生物识别技术当中,步态识别技术作为一项新兴的生物识别技术其普及程度并没有其他的生物识别技术那么高,因此其使用的便利程度并没有其他五项生物识别技术高,并且其是通过自然人的步态进行对比,从而识别自然人的身份,并且步态识别技术往往应用在“一对多”的即人流密度较大的识别场景中因而其在识别对象的准确性会受到静止物遮挡的影响,需要与其他生物识别技术结合使用。指纹识别技术、面部特征识别技术以及声纹识别技术是三项较为成熟,普及范围较广的三项生物识别技术,与面部特征识别技术和声纹技术相比,指纹识别技术无论是采集还是识别,均需要与传感器进行接触,即便如此其被盗取的风险仍然较高,他人可通过物理手段获取目标对象的指纹从而完成识别认证的过程,某一型号三星手机就因为屏幕遗留了手机所有人的指纹,使得任何人即可通过指纹解锁手机。⁶⁰

即使各项生物识别技术都有着不同的缺点,但这并不妨碍生物识别技术的大规模应用于不同的社会场景,按照生物识别技术的应用的目的进行划分,生物识别技术的应用场景可分为公领域的应用场景与私领域的应用场景两大类(见表二),生物识别技术在公领域的应用场景主要目的是维护社会的安稳秩序,而其在私领域的应用场景最主要的目的是通过以自然人生物特征为识别手段,提升其自身的生活便利程度。如表二所示,公领域的应用场景一直是生物识别技术的主要运用场景,在我国生物识别技术一直是重要的刑侦手段之一,指纹识别、基因识别、面部特征识别等生物识别技术为确定犯罪嫌疑人身份起到了重要的作用。随着生物识别技术的不断发展,生物识别技术的公领域应用场景逐渐由刑事侦查领域扩展到了安全领域包括国家安全、公共安全和社会治安,在公共场所,人脸识别技术、指纹识别技术等大规模应用于火车站、飞机场、通关口岸等

60. “三星被曝屏下指纹存在安全漏洞 罪魁祸首是手机保护膜”, 腾讯网, <https://new.qq.com/omn/20191016/20191016A03CRU00.html>, 2021年6月30日。

人流量大的地方，通过对身份的认证识别起到维护公共安全的作用。而在私领域的应用场景中，除了金融支付安全领域、视听娱乐领域外，还有营销教育等等领域，人脸识别、指纹识别以及声纹识别逐渐代替数字密码成为主流的身份认证方式，逐渐成为人们主要的设备锁控方式以及支付方式支付。

生物识别技术	便利程度	接触采集是否必须	普及	盗取难度	识别对象的准确性
指纹识别技术	高	是	高	容易	高
面部特征识别技术	高	否	高	容易	高
虹膜识别技术	中	否	低	高	高
声纹识别技术	高	否	高	容易	中
步态特征识别技术	低	否	低	高	中

表一生物识别技术的比较

表二生物识别技术的应用场景

生物识别技术	公领域应用场景				私领域应用场景		
	国家安全	公共安全	社会治安	刑事侦查	支付安全	生物锁控	娱乐视听
面部特征识别技术	√	√	√	√	√	√	√
指纹识别技术	√	√	√	√	√	√	×
虹膜识别技术	√	√	√	√	×	×	×
声纹识别技术	√	√	√	√	√	√	×
步态识别技术	√	√	√	×	×	×	×

（二）生物识别技术应用引发的侵权风险

生物识别技术的大规模商业化应用，意味着我们的生物识别信息无时无刻会被不同的信息处理集体进行搜集处理存储。如前文所述，生物识别信息是生物识别技术的产物，体现着人格尊严和人格自由的人格利益，承载着自然人的肖像、隐私等人格权益。同时生物识别技术的大规模应用也意味着其引发的侵权风险进一步提高，生物识别技术应用引发的风险可以区分为直接的侵权风险以及间接的侵权风险。

生物识别技术滥用引发的直接侵权风险则是指对自然人生物识别信息的侵犯。直接侵权风险多是发生在信息处理主体与信息所有人之间，部分生物识别技术的采集手段具

有非接触性，可实现远程识别认证自然人的身份。这也导致了部分信息处理者未遵守知情同意原则，未经生物识别信息所有人允许，隐秘地采集自然人的生物识别信息，在社交媒体领域、房屋销售领域已经成为了滥用生物识别技术的重灾区，比如前文中所举的关于 Facebook 的例子，信息处理者将互联网爬虫技术与生物识别信息技术相结合，即可在用户不知情的情况下将用户发布在社交平台中，含有面部特征的照片进行截取生成相应的生物识别信息数据库，而在我国更被曝出多家售楼处未经他人同意收集来访者的人脸识别信息。⁶¹除了秘密采集自然人生物识别信息信息，强制收集自然人生物识别信息亦是侵犯个人生物识别信息的主要手段之一，存在数量不少的移动应用程序（App），以收集个人信息为使用条件，从而收集非必要的个人信息包括生物识别信息。另一直接的侵权风险则是生物识别信息的泄露，在我国生物识别信息是通过数据的形式进行收集处理存储，数据有着极大的泄露风险，生物识别信息作为识别认证自然人的电子身份，相比密码虽然有者巨大的优势，但是其与人身紧密相连，无法更改，当发生数据泄露时，生物识别信息所有人无法像更改密码一样更改生物识别信息，而只能够进行删除，意味着一经泄露生物识别信息不在具有作为识别认证手段所应该拥有的安全性。

生物识别技术的滥用除了会侵犯公民的生物识别信息，还会导致侵犯公民的其他合法权利，深度伪造技术多运用于制作换脸视频，换脸视频给大众提供了一个娱乐途径，但同时也有可能侵犯公民的相应权利。首先可能侵犯公民的肖像权和名誉权，在国外深度伪造技术，被不法分子运用在色情视频领域，其将他人的人脸替换至色情视频中，特别是美韩的女明星是色情视频换脸的重灾区。⁶²因此生物识别技术的滥用可能会导致公民的肖像权名誉权遭受侵害。其次，深度伪造技术可能侵犯他人的知识产权，我国规定视频作者对其作品享有完整权，不受任意修改的权利；而表演者则对其表演形象享有表演者权，任何人不得歪曲其表演形象。而在换脸视频中，通常会使用深度伪造技术将他人的人脸与原视频中表演者的人脸进行替换，这本质是一种歪曲表演者形象的行为，也是对视频作品的修改，因此生物识别技术的滥用也会引起知识产权侵权风险。再者生物识别技术的滥用会引起侵犯公民财产权的风险，生物识别信息是大数据时代公民的身份验证方式之一，如本文一直所强调的生物识别信息真正替代密码，成为金融支付、设备

61. 苏晓：“售楼处人脸识别背后的‘暗战’”，中房网，<http://www.fangchan.com/news/320/2020-12-03/6740110509972198108.html>，2021年6月30日。

62. 陈志芳：“数说：AI换脸色情视频祸害了谁？韩国女偶像深受其害”，腾讯网，<https://new.qq.com/omn/20191016/20191016A0IOU700.html>，2021年6月30日。

账号解锁的重要方式之一，但生物识别信息也会成为不法分子侵犯他人财产权的工具，四川就曾出现利用生物识别技术获取他人面部特征信息，利用他人面部特征信息解锁他人支付宝账号并转移账号内的财产，⁶³在生物识别信息大规模应用在金融支付领域的今天，滥用生物识别技术会引起侵害财产权的风险。最后，滥用生物识别技术，会引起侵害平等权的风险，会引起新时代的歧视。当人们利用生物识别技术采集生物识别信息形成相对应的数据库时，并不会只采集生物识别信息，信息处理者会对自然人的其他个人信息，譬如年龄、性别、爱好等，经过各种信息的结合形成相对应的用户画像，在营销领域针对自然人的用户画像，针对其生物识别信息，分析其身体状况，做定点的广告投放，甚至提供不同的价格标准（价格歧视）。仅仅是营销领域，滥用人脸识别技术既能让商家针对用户提供不同的价格标准，遑论在政治领域，生物识别技术的滥用是否会造成识别的过程充斥者歧视与偏见，形成新时代的人格歧视，⁶⁴因此生物识别技术的滥用危害自然人的平等权。

二、生物识别信息的特殊必要性分析

通过对生物识别技术的分析以及前文生物识别信息的基本类别的列举，可以从中知悉生物识别信息具有一定的特殊性。生物识别信息的特殊性让其与隐私权、一般个人信息存在着区别。

（一）生物识别信息与一般个人信息的区别

生物识别信息是个人信息的一种，与个人信息相比，生物识别信息是个人信息的子集，二者是包含关系，正如前文所说，我国民法典中将生物识别信息纳入至个人信息的范围进行调整。但是生物识别信息有着其特殊性，导致其与一般个人信息有所不同。

第一，生物识别信息是以人的生理特征和行为特征为识别对象，从而达到对自然人身份的识别，因此其与人身具有极度紧密的关系，具有强烈的人身依附性。因此生物识别信息与个人一般信息例如电话号码、电子邮箱地址、身份证号码等相比具有显著差异，后者以信息主体的社会性特征为基础，它们外在于人本身；而前者直接反映信息主

63. 成都市郫都区人民法院（2019）川 0124 刑初 610 号刑事判决书。

64. 蒋洁，前注[14]，第 61 页。

体内在的身体、生理和行为本质属性，具有更高程度的可识别性。⁶⁵

第二，正因为生物识别信息所具有的强烈的人身依附性，这就决定了生物识别信息相比一般个人信息譬如姓名、通讯地址等一般个人信息来说是独一无二的。世界上不可能有两个完全一样的个体，即使是在面部特征相差无几的同卵双胞胎，也可从他们身上寻找出不一样的生物识别特征，比如指纹、步态、声纹等。生物识别信息反映了公民独特的人身特征，从而具备独一无二性，所以在与一般个人信息相比较，生物识别信息在识别公民身份上天然具备极强且迅速的辨识效果，而生物识别信息也逐渐替代数字密码、符号密码，成为日常生活中的主要支付密码而使用。⁶⁶

第三，生物识别信息与一般个人信息相比具有稳定性、不可更改性以及不可替代性。生物识别信息的稳定性和不可更改性是由其人身依附性决定的。生物识别信息是以人体的生理识别特征或者行为特征为识别依据的，人体的性状以及行为模式会在个体成熟后维持一段稳定的时间，并随着年龄的衰老，身体机能的退化而有所改变，但这个变化的过程是几十年时间的积累，并不是一个快速变化的过程，这就导致了生物识别信息具有稳定性，在不遭受外力的帮助下，譬如整容、大规模损伤等，个体是很难针对自身的生理特征进行改变，况且生物识别信息中的基因信息、虹膜信息以及静脉信息等是不可改变的，综上，自然人想改变自身生物识别信息并不容易，需要付出较大的身体健康、技术以及经济代价，因此生物识别信息相比一般个人信息具有稳定性、不可更改性。不可替代性是指无法以同种类的生物识别信息去替代既定信息的运用，这是由生物识别信息的独一无二性所决定且衍生出的性质。⁶⁷发生信息泄露时，自然人可以通过修改相关信息，譬如银行卡丢失可通过修改数字密码规避风险；身份证件丢失可通过挂失声明失效进行补办；电话号码本就用于社会交往活动，如不想多人获悉，可申请新的号码等。但生物识别信息的稳定性、不可更改以及不可替代性决定了生物识别信息一旦泄露，就会发生不可弥补、无法追索的后果，自然人只能通过更换生物识别信息的种类去规避风险，但其无法使用同一种类的生物识别信息予以替代，一个人不可能同时拥有两幅不一样的面孔，凡是与生物识别信息认证相关的所有活动都将永远退出，⁶⁸因此某种程度上，

65. 冉克平：“论个人生物识别信息及其法律保护”，《社会科学辑刊》，2020年第6期，第112页。

66. 王德政：“针对生物识别信息德刑法保护：现实境遇与完善路径——以四川”人脸识别案“为切入点”，《重庆大学学报（社会科学版）》，<http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.c.20200407.1725.006.html>，2021年6月30日，第2页。

67. 同上注，第7页。

68. 付微明，前注[23]，第138页。

生物识别信息是自然人的“唯一标识”。因此生物识别信息与一般个人信息相比具有稳定性、不可更改性以及不可替代性。

第四，生物识别信息与一般个人信息相比，具有技术性处理的特点，数据是其唯一的表现形式。生物识别信息对身份识别的过程可划分为，通过技术手段采集生物特征转化为数据并形成数据库，并从数据库中进行比对验证，从而识别他人的身份，因此技术处理是生物识别信息的必经程序。根据我国《数据安全法》的规定，数据是信息的载体，是对信息的记录。⁶⁹因此数据是个人信息的表现形式之一，但生物识别信息是通过技术手段转化为数据，并形成用以识别的数据库，因此数据是生物识别信息的唯一载体，一般个人信息的载体可以是数据，也可以是纸质的形式，且其形成无需经过复杂的技术处理，因此生物识别信息相比一般个人信息具有技术性处理的特点。

（二）生物识别信息与隐私权的区别

提倡生物识别信息隐私权说的学者们，多受到美国隐私权体系的影响，但不能忽视的是，美国的隐私权具有大陆法系一般人格权的作用，其囊括的范围相比大陆法系国家的隐私权要大。生物识别信息与隐私权有所交集，但之间的关系并非被包容与包容之间的关系。理论上隐私的内涵大致可分为三类，分别是个人信息资料，个人独处私生活安宁，个人自主决定私人事务、支配私人领域。总而言之凡属于个人所不希望披露且没有必要向公众披露的私人信息和事务，以及私人空间和自主决定都属于隐私的范围。⁷⁰因此私密性是隐私的最大特性，我国民法典也规定了个人私密信息由隐私权的规范进行调整处理。

第一，生物识别信息强调的是信息主体对其自身生物识别信息支配、控制以及自主决定的利益，生物识别信息中有属于信息主体所希望不为人知的信息，比如基因信息等。但值得注意的是，也有部分生物识别信息并没有私密性的特征，部分生物识别信息属于标表性的生物识别信息，即普通人可在平时正常的社会交往活动中所接触，并且广泛公开应用，比如人脸识别信息、指纹识别信息的，这些生物识别信息多被用于社会身份认证识别活动，一经公开，并不存在私密性。因此生物识别信息与隐私权之间并不相等，而是属于相互交叉的关系。

69. 《中华人民共和国数据安全法》第三条第一款：“本法所称的数据，是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。”

70. 沈中、许文洁，前注[38]，第80页。

第二，两者间的法律属性并不相同，所涉及的利益性质也不尽相同。隐私权已被我国从一项民事利益升格为一项权利，并将其视为具体的人格权予以保护，从权利属性角度上，隐私权属于绝对权，拥有着绝对的支配排他的利益，并且隐私权作为一项人格权利，属于纯粹的私人利益，并不蕴含公共利益。针对生物识别信息，本文第一章第一节中，已论述生物识别信息的法律性质，笔者认为在我国现行的民法规范体系下生物识别信息的本源法律属性是民事利益，并且由于生物识别信息被广泛应用于社会管理中，生物识别信息已经不是单纯的私益，其逐渐带有公共利益的属性，是私人利益与公共利益的结合。

第三，两者之间的商业价值不一样。隐私权主要是一种精神性的人格权，其财产价值并非十分突出，隐私主要体现的是人格利益，侵害隐私权也主要导致的是精神损害。⁷¹隐私权是个体对自身私密事务信息，私生活安宁的自主权利，这些利益给隐私权人带来的是其精神上的安宁，隐私权若被侵犯给权利人带来的更多是精神上的损失，且隐私权并不能被商业化利用。针对生物识别信息，笔者虽然认为其本身并不含有财产价值，但生物识别信息的载体即数据本身是可被商业化利用的，因此隐私权与生物识别信息相比，是否能商业化利用是两者之间的差别。

生物识别信息作为一项民事利益，虽然在我国现行民法规范下并未升格成为权利，但其客体关乎人格尊严与人格自由，生物识别技术的滥用给生物识别信息所有人带来了一定的侵权风险，不仅仅是对生物识别信息的侵犯，还包括利用生物识别信息对他人其他权利的侵犯。另外由于生物识别信息的人身依附性，导致其与一般个人信息有着明确的差异。而生物识别信息明显缺乏的私密性也导致了其与隐私权之间虽有交集，但存在着明显的差别。

71. 王利明：“论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心”，《现代法学》，2013年第4期，第66页。

第二章 我国生物识别信息的民事保护现状与困境

根据工信部的统计,目前有近 40 部法律、30 多部法规,以及近 200 部规章涉及个人信息保护,立法数目众多,但多为行政立法,立法的侧重点也在于规定网络服务商的行政义务。⁷² 2016 颁布的《网络安全法》第七十六条规定了个人信息的外延,认为个人生物识别信息属于个人信息的一类,这是第一次从立法保护的角度,对生物识别信息作出相应的规定,也是首次在法律层级上明确生物识别信息的保护,虽然《网络安全法》本质上针对的是网络运营者的行为所作出的规定,具有公法性质,但其还是含有一定的民法性质的条款,比如第七十四条规定了违反网络安全法给他人造成损害的,承担民事责任。从信息保护的角度来说,《网络安全法》是第一部含有生物识别信息保护目的的法律。

第一节 我国生物识别信息民事规范保护的现状

《网络安全法》中虽有规定相应侵犯他人权利承担民事责任的条款,但这些条款更多是一种宣示性质的条款,对侵权行为、归责原则以及损害的认定并没有一个明确的规定。2016 年颁布的《民法总则》在第一百一十一条中,规定了个人信息是民法保护的主体,这是首次在民法的层面确定个人信息属于法律值得保护的主体。但民法总则并未提及生物识别信息,个人信息的外延也没有明确的规定。随着《民法典》的颁布,生物识别信息被明确为个人信息的一类。而《个人信息保护法》的出台意味着在生物识别信息的立法保护模式上,采取了世界主流的综合立法模式。目前涉及生物识别信息的民事保护规范主要有《民法典》的相应规定以及《个人信息保护法》中关于生物识别信息类别和侵权责任规范。关于生物识别信息的民事保护可以由三个角度进行分析,分别是人格权规范对生物识别信息的保护、合同法规范对生物识别信息的保护以及侵权责任法规范对生物识别信息的保护。

72. 秦成德、危小波、葛伟:《网络个人信息保护研究》,西安:西安交通大学出版社 2016 年版,第 254 页。

一、民法典人格权编对生物识别信息的保护

《民法典》将个人信息放在人格权编，与隐私权合并成为单独一章，即立法者认可个人信息的人格利益属性，而生物识别信息作为个人信息的一类，当然也受到人格权制度的保护。目前我国并未明确区分肖像、声音与人脸识别信息和声纹识别信息之间的区别；而与隐私权相关的民事规范中，将私密信息归类为隐私权其中一项权利内容，而生物识别信息与私密信息在范围上存有交叉。因此在《民法典》人格权编中可通过个人信息保护规范、隐私权规范、肖像权规范以及人格权禁止令制度对生物识别信息进行保护。

（一）个人信息保护规范对生物识别信息的保护

个人信息规范对生物识别信息规范的保护主要通过《民法典》与《个人信息保护法》进行，如前文所述，民法典将生物识别信息作为个人信息的一类，自然就应该受到《民法典》中关于个人信息规范的保护。《民法典》第一千零三十五条与第一千零三十六条是分别针对个人信息的处理原则以及信息处理者免责事由所作出的规定。民法典规定信息处理者处理个人信息应该遵循合法、正当、必要原则、适度处理个人信息原则以及公开、透明处理个人信息原则，实施处理个人信息的行为除了法律另有规定的情况下应该获得信息主体的知情同意。在《个人信息保护法》中对个人信息处理的原则作出了进一步的说明。正当合法必要和诚信原则，要求信息处理主体应当通过合法的途径去处理个人信息，以误导欺诈胁迫等方式处理个人信息的行为是不被法律所许可的。而《个人信息保护法》中新增了合乎目的原则，并且将合乎目的原则与适当处理原则合并在一起，要求信息处理者处理个人信息的目的应该合理明确，处理个人信息的行为应该符合其像信息主体所公示的目的，且处理信息对信息主体权益所造成的影响应当在最小的限度之内。而公开透明原则要求信息处理主体公示其处理规则、处理目的、方式以及范围。这些个人信息保护的基本原则的精神贯穿着《民法典》个人信息保护条文以及《个人信息保护法》全文。

针对信息处理者的行为义务，《民法典》第一千零三十八条以及第一千零三十九条进行了详细的规定，前者规定了信息处理者的行为义务，即信息处理者负有妥善保管个人信息的义务，应当采取必要的保护措施，不得泄露篡改或者未经信息主体允许向第三人提供个人信息等义务；而后者则是规定公权力机构对因履行职责所获悉的个人信息含

有保密义务。而在《个人信息保护法》中，对个人信息的处理义务做了更加详细的规定。除了《民法典》业已规定的信息处理者应当采取必要保护措施义务以及保密义务外，还新增事前影响评估义务、发生信息泄露事故后的补救措施义务以及个人信息处理者的合规审计义务。而《民法典》中所规定的不得泄露篡改丢失个人信息的义务，在《个人信息保护法》中得到了明确的要求，为了防止泄露丢失篡改个人信息，信息处理者负有制定相应管理制度、对个人信息进行分类保护、采取相应的安全技术、对从业人员的培训以及制定应急预案等等的义务。基于为了保障信息的自由流通，防止信息处理者负担义务畸重，而阻碍相关行业的发展，《民法典》第一千零三十六条同样规定了信息处理者处理个人信息的免责事由，如果信息处理者是在信息主体知情同意的范围内处理个人信息、处理业已公开的个人信息且信息主体并未明示反对以及处于维护社会公共利益的需要，在这三种情形下可免除信息处理者的民事责任。

除了规定个人信息处理的原则，信息处理者的行为义务，我国也赋予了信息主体一部分权能，增强其对个人信息的控制与支配。《民法典》第一千零三十七条所规定的就是信息主体对其个人信息所享有的权能，我国信息主体对其个人信息享有查阅、复制、更正补充以及删除等权能。而《个人信息保护法》对查阅、复制、更正补充以及删除权做了详细的说明补充外，还明确了信息主体享有知情权、决定权，以及有权请求个人信息处理者对信息处理规则进行解释说明。针对自然人死亡后，其个人信息利益的保护问题，《民法典》虽然没有明确的规定，但在《个人信息保护法》，也明确规定了自然人死亡后其个人信息的保护问题，众所周知，自然人的权利能力始于出生，终于死亡，而自然人死亡后，其对其个人信息所享有的一切权利也终究会消失。《个人信息保护法》第四十九条就规定了，自然人死亡后，其近亲属出于保护自身合法正当利益的目的，可以替代死者，对死者的个人信息享有查阅、复制、更正以及删除权等。

上述是《民法典》与《个人信息保护法》对个人信息保护所作出的一些规定，生物识别信息作为个人信息的一类，上述法律所规定的个人信息保护法律条文一定也会对生物识别信息起到保护的作用。但正如在本文前半部分所论述的，生物识别信息作为个人信息的一类，可识别性是其与其他一般个人信息的共性，而与高度的人身依附性、不可更改性是其与其他个人信息的最大差异。在《民法典》中并没有对生物识别信息作出特殊的保护规定，生物识别信息在《民法典》中处于概括性保护的状态。在《个人信息保护法》意识到了部分类别个人信息的特殊性，于是将个人信息区分为一般个人信息与敏

感个人信息，将敏感信息定义为一旦遭到泄露，容易导致侵害人格尊严以及危害人身安全、财产安全的个人信息，而生物识别信息由于其高度人身依附性以及被大规模应用在支付安全、公共安全和国家安全等领域，所以生物识别信息也被划分为敏感个人信息之中。⁷³并且《个人信息保护法》针对敏感个人信息设立了敏感个人信息的处理规则。相对于一般个人信息的处理规则，敏感个人信息的处理规则更为严格，在处理程序的启动上，信息处理者需保证目的的充分必要以及保护措施严格，才可开始处理个人敏感信息；在知情同意的规则上，信息处理者必须获得信息主体的单独同意，如果法律、行政法规对知情同意的形式有着更进一步的要求，信息处理者应该遵从法律法规的其他规定；除此之外信息处理者还有更严格的说明义务。因此在《民法典》中关于个人信息的制度，赋予了生物识别信息的概括性地保护状态，而《个人信息保护法》的出台让信息处理者的处理义务更为严格，也更好地保护了生物识别信息。

（二）肖像权规范对生物识别信息的保护

生物识别信息是以人体的生理特征和行为特征为识别对象信息，因此正如本文前述的那样，人脸识别信息与声纹识别信息属于生物识别信息的一种。而面部特征作为人脸识别信息的识别对象，不可避免的会与肖像利益结合在一起。在我国肖像利益业在《民法通则》中已被上升为一项民事权利予以保护，当时对侵犯肖像权的行为规定必须以营利为目的，《民法典》出台之后肖像权的侵权要件不再要求以营利为目的。肖像的定义是通过其他手段，将自然人的人脸复现在其他载体中的图像，比如照片、雕像、视频录像等等，皆可以生成肖像。而人脸识别信息的产生也离不开肖像，部分人脸识别技术在采集阶段需先生成自然人的人脸图像，这个过程本质上即是肖像生成的过程，其后对所采集的图像进行相对应的分析，对图像上人脸的轮廓位置进行分析转化为数据，而深度伪造技术更是在显现肖像的视频中进行相对应的操作。肖像与人脸识别信息相比，两者之间都有可识别性的特点，皆是起到对自然人身份识别的作用，但两者不同的地方在于肖像权着重的是对人脸图像的保护，而生物识别信息则是对人脸图像进行特征分析技术处理后所生成的人脸识别信息，也就是这一数据的保护。综上，未经个人信息处理者同意采集其人脸识别信息的，既可能构成侵犯生物识别信息，也可能构成对肖像权。因

73. 《个人信息保护法》第二十八条第一款：敏感个人信息是一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人信息，包括生物识别、宗教信仰、特定身份、医疗健康、金融账户、行踪轨迹等信息，以及不满十四周岁未成年人的个人信息。

此作为生物识别信息的人脸识别信息与肖像之间既有关联，又有区别。为了区分肖像权与个人信息，不少国家或者地区决定将照片和视频，排除出生物识别信息。正如在第二章所提到的一样，美国的 BIPA 就明文规定照片视频不属于生物识别标识符，但通过技术处理图片视频所获得的人脸模板或者人脸识别信息属于生物识别信息。而欧盟的 GDPR 虽然在正文中没做出要求，但其在序言的第 51 条中，也提到不应该将对自然人照片的处理当然地认为是一种特殊类别个人信息的处理，只有对图片的处理采用了一定的技术手段，使得对自认人身份的辨识达到一定的可识别性，才可以将对图片的处理归结为特殊类别个人信息的处理。我们可以看到无论是欧盟还是美国，都尽量地将人脸识别信息与肖像相区分，但是由于技术的发展，对照片视频的自动截取技术愈来愈成熟，人脸识别信息与肖像之间关系是紧密相连而又有区别，无论是我国的《民法典》还是《个人信息保护法》并没有像美国或者欧盟一样，对图片、视频和人脸识别信息做一个划分，而对人脸的采集形成图像的一个过程，本质上也是一个肖像制作生成的过程，因此对于生物识别信息中的人脸识别信息可以适用《民法典》肖像权的规定，《民法典》第一千零一十九条规定不得利用信息技术手段侵还他人肖像权，这一条规定，被认为是对深度伪造技术的规制。同理，声纹识别信息也可以适用《民法典》中肖像权的有关规定，在《民法典》的地一千零二十三条第二款中，规定了对自然人声音的保护，参照适用肖像权保护的有关规定。

（三）隐私权规范对生物识别信息的保护

《民法典》中虽然没有针对个人信息的敏感性进行一个区分，但对个人信息的私密性进行了一个区分。《民法典》人格权编将隐私权和个人信息分为同一章节。对于我国隐私权的内涵，民法典认为“私人生活安宁”、“私密空间”、“私密活动”以及“私密信息”这四项内容构成了隐私权的权利内容，这四项内容的共同点即是强调私密性，因此私密性是隐私权的最大特性，个人私密信息可以受到隐私权规范的调整与保护。生物识别信息属于敏感信息，但是敏感信息并不等同于私密信息，在本文第一章就对生物识别信息与隐私权之间的关系做过相应的论述，生物识别信息与隐私权是相互交叉，有着相关联的地方，但又不完全相同。正如前文所述，生物识别信息是由多种类别的生理特征识别信息和行为特征识别信息组成的，像人脸识别信息、声纹识别信息等标表性识别信息，由于其本身的外在性以及交流性，其自身并不具有私密性，即是具有私密性，

也是因为其与其他私密信息相结合,致使其具有私密性。但部分生物识别信息,比如基因信息,能够反应人体的身体健康状况,且常常与医疗健康信息相结合,对基因信息的识别,除了能对自然人身份进行识别,还能对人体的身体健康状况、疾病情况以及家族遗传情况进行一定的识别,因此部分具有私密性的生物识别信息可以受到隐私权的保护。《民法典》第一千零三十四条第二款,就是关于对私密信息的保护规定,该条规定明确了,私密信息可以适用隐私权的有关规定,而个人信息保护制度则作为兜底的保护措施,当隐私权并未对相应的具有私密性的生物识别信息予以保护时,即可由个人信息的保护制度进行保护。

(四) 人格权保护禁止令制度对生物识别信息的保护

人格权保护禁止令制度是《民法典》新增的针对人格权而设立的一项保护制度,根据《民法典》第九百九十七条的规定,人格权主体若能证明行为人的行为属于正在或者即将侵犯人格权的违法行为,可以向法院申请有关的保护禁止令措施。人格权禁止令的启动条件有以下几点要求:

一是侵犯对象的特定性,行为人所实施或者将要实施的违法行为,是针对人格权而实施的,人格权保护禁止令制度只规制侵犯人格权的行为,侵犯其他财产权或者债权的行为,并不能适用人格权保护禁止令制度。

二是迫害的紧急性以及损害的难以弥补性,人格权保护禁止令不同于其他的行为保全措施,人格权保护禁止令是一项具有终局性的措施,一经作出永久有效。人格权保护禁止令制度的作出是永久有效的,不会像知识产权禁止令或者其他行为保全措施一般,超过法定期限不起诉即失效,这意味着法院颁布人格权保护禁止令需审慎,只有当权利人的合法权益所遭受的损害在不及时制止的情况下难以弥补,才可以颁布实施。

三是申请程序以及采取措施主体的法定性。人格权保护禁止令这一措施只能有民事主体申请,而申请的前提是民事主体有相应的证据证明相关侵权行为的存在以及对损害的危害后果,即民事主体对人格权保护禁止令的申请承担着相应的证明责任。采取措施的主体只能是人民法院,申请人只能依照法定程序向人民法院申请。

相对于正常的民事诉讼途径,由于人格权禁止令制度一经作出即永久有效,且无需像正常的诉讼一样经历一审二审程序,因此对于权利人来说这是一项强有力的保护措施。对于如何理解九百九十七条中人格权的含义,是将其理解为指代绝对权的人格权还

是对条文中的人格权作出扩大解释，将其解释为人格权益，生物识别信息是否可适用人格权保护禁止令的问题，本人认为生物识别信息可以适用人格权保护禁止令制度。从立法体例上看，人格权保护禁止令制度是在人格权编的一般规定一章中，一般规定这一章在人格权编中起着总则的作用，对全编的人格权益的起着补充作用。另外，在最高院出台的关于人脸识别信息司法解释中，第九条是明确了人脸识别技术受人格权保护禁止令制度的规制，在第九条中提到利用人脸识别技术侵犯他人隐私权和其他权益的，经他人申请人民法院可以采取人格权保护禁止令，解释中所采用“其他权益”的描述，意味着人格权禁止令制度是对权利的保护外同时也是对利益的保护，因此生物识别信息作为民法保护的一项利益，当然适用人格权保护禁制令措施。

二、民法典合同编对生物识别信息的保护

无论是《民法典》还是《个人信息保护法》皆强调处理个人信息应该获得信息主体的知情同意，而生物识别信息这一类敏感信息的处理，更是需要获得信息主体的单独同意。信息主体知情同意的形式，在《民法典》以及《个人信息保护法》中也没强制性的要求，只是规定敏感信息处理如果其他法律法规要求获取信息主体书面同意的，才遵循其他法律法规的规定。而信息处理者为了获取信息处理者的知情同意，往往会采用许可服务协议以及网络隐私政策告知等方式，来获取信息主体的知情同意。采用许可服务协议，信息处理者会在许可服务协议中将个人信息的相关内容特设为一个章节，信息主体同意认可许可服务协议的相关内容后，处理者和信息主体之间必然会成立一个合同关系。许可服务协议中，信息处理者有义务将收集处理生物识别信息的目的以及范围、信息的留存期限以及承诺在不存在法定的情况下不会向第三方透露转移信息主体的生物识别信息等。

除了许可服务协议，在网络活动中，个人信息处理者通常会采用网络隐私政策来获取信息主体的知情同意。网络隐私政策，也称隐私政策，它是指网络服务提供者以在线文件的方式披露其收集、利用用户个人信息的目的、范围和方式等内容，并公示其保护用户个人信息的原则和具体措施。⁷⁴网络隐私政策产生的诱因是《网络安全法》第四十一条的规定，《民法典》颁布生效前，主要依靠《网络安全法》对网络活动中的个人信

74. 王叶刚：“论网络隐私政策的效力——以个人信息保护为中心”，《比较法研究》，2020年第1期，第121页。

息处理行为进行规制，在其第四十一条的规定，要求在收集处理个人信息是要明示相应的目的，因此网络隐私政策应运而生，在前文所提及的《信息安全技术规范》中即有隐私政策相应模板。网络隐私政策的告知，是否能引起信息处理主体与信息主体之间存在合同关系存疑。因为部分信息处理者设立网络隐私政策的目的是为了告知信息主体，而并没有设立是否同意选项，又或者即使设立了是否同意的选项，但信息处理者若不同意，也无法正常适用功能。笔者认为经用户同意的隐私政策效力可以引起信息处理主体与信息主体之间的合同关系，即使网络隐私政策未提供是否同意选项给予用户，但在实践中网络隐私政策往往会与许可服务协议相结合，比如腾讯的微信支付服务许可协议。

无论是许可服务协议还是设置了是否同意选项的网络隐私政策，均能引起信息处理者与信息主体之间的合同关系，毫无疑问，生物识别信息的处理行为应当遵循约定。而许可服务协议或者网络隐私政策在这个时候当然属于一份格式合同，同样受到民法典合同编中的制约，在许可服务协议或者网络隐私政策中，对信息主体的权利进行不正当的约束或者限制的，应该适用民法典第四百九十七条的规定，加重对方责任、限制对方主要权利的格式条款无效。而最高人民法院也持有相同的观点，在其颁布的《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》的司法解释中第十一条也规定了信息处理者采用格式条款要求自然人进行无期限限制、不可撤销、可任意转授权信息性处理者处理人脸识别信息，自然人可根据民法典四百九十七条申请相应的格式条款无效。因此，当信息处理主体违反许可服务协议或者网络隐私政策时，信息主体可以根据民法典，追究信息处理者的违约责任。

三、民法典侵权责任编对生物识别信息的保护

个人信息的入典意味着个人信息是民法值得保护的一项利益，我国的侵权责任法规范既保护权利，也保护民事利益，侵权法保护的民事利益包括人身利益与财产利益，生物识别信息作为个人信息的一类，当然也受到侵权责任法规范的保护。在《民法典》中并没有对生物识别信息的归责原则作出一个详细的规定，如果侵权行为是发生在网络上的，则可以推定适用网络侵权责任的相应规范。针对人脸识别信息最高法在《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》

的司法解释也明确了网络处理人脸识别信息的，适用网络侵权责任的相关规定。⁷⁵这也意味着对利用网络服务处理人脸识别信息的，没有遵守法律或者信息处理者与信息处理人之间的约定的，责任主体可以是网络服务提供者以及利用网络服务实施侵权行为的网络用户。如果实施侵权行为人是网络服务提供者，那么人脸识别信息所有人，可以就侵权行为适用网络侵权责任的相关规定，请求网络服务提供者承担民事责任。如果网络服务提供者并非直接侵权行为人，而是网络用户利用网络服务实施了相应的侵权行为，那么责任主体就是网络用户以及网络服务提供者，网络服务提供者当履行了相应的通知规则后，可不承担侵权责任，否则需要对不履行通知规则而造成损害扩大的部分承担连带责任。

网络侵权责任虽然是作为一项特殊的侵权责任制度，但其归责原则适用的是一般过错责任归责原则，但如果采用过错责任的归责原则，则需要信息主体证明信息处理者在处理生物识别信息的过程中存在过错，而在证明能力上，作为个体的信息主体和信息处理者相比，其证明能力相对于信息处理者来说明显较弱，如果采用过错责任的归责原则，则不利于生物识别信息的保护。而立法者明显考虑到在个人信息处理活动中信息处理者和信息主体双方对信息的控制支配能力是不对等的，因此《个人信息保护法》第六十九条规定了侵犯个人信息的归责原则适用过错推定的归责原则。在个人信息侵权案件中，信息处理者的证明自身无过错的，才可不承担相应的损害赔偿赔偿责任，因此一般情况下，侵犯生物识别信息可以适用过错推定的归责原则，通过举证责任倒置的方式减轻信息主体的证明责任，从而达到在侵权责任法上保护生物识别信息的目的。司法解释规定了网络处理人脸识别信息适用适用网络侵权责任的相关规定，在民法典侵权责任编的网络侵权责任条文中，设立了引致性条款，其他法律对网络侵权责任有其他规定的可以适用其他法律的相关规定，《个人信息保护法》既然规定了信息处理过错推定的归责原则，那么网络处理人脸识别信息的当然也应当适用过错推定的归责原则。

在诉讼模式上，《个人信息保护法》设立了对个人信息侵权的民事公益诉讼，而生物识别信息作为个人信息中的一类，检察机关、经过授权的消费者组织以及网信办决定的相应组织当然可以针对生物识别信息的侵权行为提起公益诉讼。公益诉讼的基本目标是维护社会的公共利益，生物识别信息常被用于社会安全、公共安全领域，其当然具有

75. 《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》第七条第二款：信息处理者利用网络服务处理人脸信息侵害自然人人格权益的，适用民法典第一千一百九十五条、第一千一百九十六条、第一千一百九十七条等规定。

相应的公共利益，由于生物识别信息的技术处理性，决定了数据是生物识别信息的唯一载体，与信息处理者相比，信息主体的探知和技术能力较弱，单纯依靠私益诉讼并不能很好地保护信息主体的生物识别信息不受侵犯，免遭泄露的风险，而检察院、经过授权消费者组织以及经过网信办确定的组织，或许依靠相应的公权力或许拥有者丰富的技术能力，在诉讼过程中有着跟信息处理者相等或者远超于的能力，因此设立相应地民事公益诉讼更能保护生物识别信息。

第二节 我国生物识别信息民事司法保护现状

生物识别信息已经大规模运用于我们的社会生活当中，虽然我们认为生物识别信息与一般个人信息具有明显的差异性，但是不可忽视的现实是生物识别信息往往会和其他一般个人信息相结合，因此在我国司法实践中，纯粹的因为生物识别信息而引起的民事纠纷较少，笔者以“生物识别信息”、“民事案由”为关键字在北大法宝案例库进行搜索，共搜涉及关键字“生物识别信息”的民事案例共 36 个，但是其中审判内容涉及生物识别信息的寥寥无几，大部分关键词的出现是因为法院在审理过程中需要对个人信息的概念范围作出界定，或者引用民法典中有关个人信息概念的条文，庭审核心仍然是个人信息，而不是生物识别信息。虽然与生物识别信息相关案例较少，但是个人信息作为生物识别信息的上位概念，法院审理过程中的相关判决思路仍然值得借鉴。

一、对“合法正当必要原则”的阐述

在这 36 个案例之中，与生物识别信息相关联的案例为郭兵诉杭州野生动物园人脸识别案（以下简称“郭兵案”），郭兵根据《消费者权益保护法》第二十六条关于格式条款的有关规定以及第二十九条关于消费者个人信息保护的规定，请求人民法院判定杭州野生动物园公示以及短信中关于强制指纹识别以及人脸识别的内容无效，请求判决杭州野生动物园删除其所收集郭兵包括生物识别信息以及入园信息等所有个人信息。法院的观点认为《消费者权益保护法》规定了个人信息的收集利用应该遵循“合法正当必要原则”，法院认可被告方利用指纹识别、人脸识别的验证方式提升入园效率符合合法正当必要原则，但是应获得对方的知情同意。野生动物世界在涉指纹识别的“年卡办理流程”中规定流程包含“至年卡中心拍照”，但其并未告知郭兵与其妻子拍照即已

完成对人脸识别信息的收集及其收集目的，违反了知情同意原则，郭兵请求动物园删除人脸识别信息理由正当；而短信的内容本质上是对合同的变更，郭兵明确不予认可，因此短信内容对郭兵不发生效力。⁷⁶“郭兵案”是一起典型的侵犯生物识别信息的案子，法院认可了经营者为了提高经营效率提升服务的需要而收集生物识别信息的行为具有“合法正当必要性”，但是法院也明确指出了“合法正当必要”的边界是由信息主体决定的，收集生物识别信息的范围不应该超过信息主体知情同意的范围，案例中杭州野生动物园以制作年卡需要照片为由，对郭兵夫妇进行拍照的行为获得了郭兵夫妇的同意，但是将所获取的照片数据作为人脸识别的信息模板则超出了郭兵夫妇所同意的范围，因此收集生物识别信息的“合法正当必要”其中一个要求就是符合信息主体的知情同意。除了“郭兵案”，王会会与奚红侵权责任纠纷案以及潘鑫涛诉姚骏安装可视门铃侵害隐私权纠纷案皆是因为可视门铃所引起的纠纷，前者法院认为奚红所在的楼道已有相应的安保措施，其在家门口设置摄像头虽然是出于安全的目的，但是其在未获得王会会的同意下，所安装的摄像头会摄取王会会的面部特征，而且也容易造成面部特征的泄露，已经超过安装得必要性；⁷⁷而后者的审判法院也认为被告为保障自身的人身财产安全，在自家入户门口安装可视门铃，其行为本身具有相应的合理性，但是也负有不妨害他人合法权益的注意义务，可视门铃能摄取他人行为、日常生活以及面部特征的信息，而被告未经原告同意对上述信息进行记录，即使主观上不存有故意，但业已侵犯他人的隐私权，被告应该对门铃安装的位置以及指向负有注意义务，因此行为超过“合法正当必要性”。⁷⁸苏州贝尔塔数据技术有限公司与伊日克斯庆一般人格权纠纷案中，二审法院认为转发他人网络上业已公开的个人信息并不违反“合法正当必要性”，但是当信息主体向转发者提出删除，而转发者不予理会时信息主体对信息传播控制的人格权益显然高于已经合法公开的个人信息流通所产生的潜在财产权益，个人信息主体对其个人信息传播控制的权利更不因个人信息已经合法公开而被当然剥夺。⁷⁹由此在上述相关案例中案件中法官都明确了“合法正当必要性”的边界，即获得信息主体的知情同意且不得妨害信息主体的合法权益，而这也意味着，信息处理者对信息的处理收集即使经过了信息主体的同意，或者所获取的信息是依照法定途径公开的信息，信息主体对其个人信息仍有着一定的支

76. 杭州市富阳区人民法院(2019)浙 0111 民初 6971 号民事判决书。

77. 苏州市吴江区人民法院(2020)苏 0509 民初 16063 号民事判决书。

78. 江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02 民终 307 号民事判决书。

79. 江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏 05 民终 4745 号民事判决书。

配与控制的权能，信息主体可以依照其意志决定生物识别信息的适用范围以及删除。即使获得信息主体的知情同意，信息处理者处理信息时也负有维护信息主体合法权益的义务。当信息处理者超出约定范围处理生物识别信息，或者信息处理者是转发他人业已公开的信息，在信息主体未请求删除时是具有合法正当性的，当信息主体请求删除，而信息处理者不为所动时，上述的行为即已造成对个人信息权益的侵犯。

二、对“财产损失”的支持

前文所提及的苏州贝尔塔数据技术有限公司与伊日克斯庆一般人格权纠纷案中，原告伊某对其主张的经济损失并没有提交相应的证据证明，但一审法院和二审法院皆根据情况酌定金额。除了该案例，还有凌某某诉北京微播视界科技有限公司隐私权个人信息权益网络侵权责任纠纷案、⁸⁰孙某1与深圳市中洲宝城置业有限公司深圳市中阳正置投资有限公司人格权纠纷案、⁸¹黄某诉腾讯科技（深圳）有限公司等隐私权个人信息权益网络侵权责任纠纷案、⁸²孙某与北京搜狐互联网信息服务有限公司等人格权纠纷案、⁸³邓某与北京顺丰速运有限公司隐私权纠纷案以及付全贵与北京三快信息科技有限公司等网络侵权责任纠纷案。⁸⁴这些案例的法院都支持原告的财产损害赔偿，即使部分案件中的原告没有证据证明其所主张的经济损失，人民法院也会依据事实情况对经济损失的数额进行酌定。由此可见在个人信息的侵权纠纷案件中，法院对于信息主体所主张的财产损失、经济损失的认定并不严苛，其可以根据庭审过程中对侵权行为的认定，以及对当事人的影响，酌情决定财产损失的赔偿金额。

三、对“精神损害”的谨慎

上文提到的邓某与北京顺丰速运有限公司侵权责任纠纷案以及付全贵与北京三快信息科技有限公司等网络侵权责任纠纷案，案例中的原告除了提出财产损害赔偿，同时又提出了精神损害赔偿，如前文所述法院支持了他们财产损失的请求，但对于他们的精

⁸⁰ 北京互联网法院（2019）京 0491 民初 6694 号民事判决书。

⁸¹ 广东省深圳市宝安区人民法院（2019）粤 0306 民初 14198 号民事判决书。

⁸² 北京互联网法院（2019）京 0491 民初 16142 号民事判决书。

⁸³ 北京互联网（2019）京 0491 民初 10989 号民事判决书。

⁸⁴ 北京市第三中级人民法院（2020）京 03 民终 2049 号民事判决书；北京互联网法院（2018）京 0491 民初 1905 号民事判决书。

神损失，皆以无证据证明侵权行为引发明显的精神痛苦，而被驳回。除此之外在吴萌薇与陈晓梅深圳大家坛信息技术有限责任公司网络侵权责任纠纷案中，原告向法院主张精神损害赔偿，虽然法院认定了被告有着泄露个人信息侵害他人名誉权的行为，但是仍需要原告对自身是否遭受严重精神损害承担证明责任，因此法院并未支持请求精神损害的主张。⁸⁵潘子冰与贵州仟佰策文化传媒有限公司、袁健虹隐私权纠纷一案、⁸⁶俞某诉北京乐某达康科技有限公司等网络侵权责任纠纷案、⁸⁷郭某与东方黑马资本管理（北京）有限公司个人信息保护纠纷案、⁸⁸陈某与上海瑞慈瑞兆门诊部有限公司隐私权纠纷、⁸⁹法院同样认可侵犯个人信息权益的行为存在，但是上述案件中，皆只主张的损害赔偿皆是精神损害赔偿，对于精神损害赔偿，法院皆要求被害者对是否遭受严重精神损害的损害事实承担相应的证明责任。

通过上述案件的列举，我们可以知悉无论是个人信息也好还是生物识别信息也好，在民法典出台以前，个人信息权益纠纷的案由可以分为两大类分别是合同纠纷类以及侵权纠纷，信息侵权纠纷的案件中法院一般通过网络侵权责任的有关规定、最高院出台的关于利用信息网络侵犯人身权益的司法解释以及具体人格权的有关规定予以调整。在损害赔偿上，法院对财产损害的事实认定较为宽松，而对精神损害的认定标准较为严苛，即使当事人未能提供实质损害的证据证明实质损害的存在，人民法院也会根据侵权行为的性质、侵权人是否因此存在获利的可能等多方面对损害赔偿的金额进行考量。针对精神损害赔偿，法院的态度则十分谨慎，往往会要求信息主体提供受到“严重精神损害”的证据，即使法院认可对原告所提及的精神损害的主张，更多是因为对个人信息的泄露，而导致他人名誉权的受损，即上游损害事实被下游损害事实所吸收。

第三节 我国生物识别信息民事保护的困境

结合我国生物识别信息民法保护以及司法保护的现状，我们可以总结得出在立法保护上，除了在《民法典》，其他有所涉及生物识别信息的民法保护规范就是《个人信息保护法》以及最高法出台的关于人脸识别信息纠纷的司法解释。从中看出，目前我国生

85. 天津市南开区人民法（2020）津 0104 民初 4719 号民事判决书。

86. 贵州省贵阳市观山湖区人民法院（2020）黔 0115 民初 11201 号民事判决书。

87. 北京市海淀区人民法院（2018）京 0108 民初 13661 号民事判决书

88. 北京市第二中级人民法院（2021）京 02 民终 10830 号民事判决书。

89. 上海市普陀区人民法院（2020）沪 0107 民初 5934 号民事判决书。

物识别信息的民事保护规范有以下几个特点：（1）注重单一类别的生物识别信息保护，如前文所述，《个人信息保护法》中将生物识别信息纳入敏感信息中，通过生物识别信息最高法针对人脸识别信息纠纷出台了相应的司法解释，对侵权行为人的责任承担方式、适用哪一类特殊侵权责任以及对损害结果的认定归责都作出了相应的解释或者宣示。（2）规范体系较为完整，由《民法典》到《个人信息保护法》，对生物识别信息的保护，可以看到在逐渐完善。由此看出对生物识别信息的民事立法保护，在呈现出有无到有，由分散式立法保护向综合立法保护的模式发展。

在司法保护上，生物识别信息纠纷所牵涉的客体繁多，因此在司法实践中，当事人适用的请求权基础不同，因此服务合同纠纷或者侵权责任纠纷是生物识别信息司法实践中经常适用的保护规则，但无论是侵权责任纠纷还是服务合同纠纷，“合法正当必要”仍然是判断标准。结合立法与司法现状上看，我国生物识别信息的民法保护仍存有几大困境。

一、未明确生物识别信息的法律概念

生物识别信息作为一个法律上的概念，或者说个人信息的类别，很早就出现在我们的立法视野当中，但无论是《民法典》还是《个人信息保护法》并没有对生物识别信息的内涵及其外延作出一个明确的规定。能明确生物识别信息的外延的规范性文件是本文第一章中所提及到的《个人信息安全规范》，而明确了生物识别信息的内涵和外延的规范性文件则是《生物特征识别信息的保护要求（征求意见稿）》。但是《个人信息安全规范》虽然采用不完全列举式的方法规定了生物识别信息的范围类别，但是作为国家行政部门出台的规范性文件，其本源属性是一个国家标准并没有强制效力，司法机关对生物识别信息的界定只能进行参考，而后者虽然对生物识别信息的概念作出了明确的规定，但是首先其仍处于征求意见阶段，并未正式颁布；其次其法律地位与《个人信息安全规范》一样属于国家标准，缺乏执行的强制效力，最后在对生物识别信息概念的界定上，以提出将生物特征识别数据等同于生物识别信息，提出生物识别信息本质上是生物特征识别数据的数据集，会造成概念的混淆。

由于未明确生物识别信息的内涵及其外延，导致生物识别信息的表述形式繁多，分类不明。涉及生物识别信息的法律规范除了《民法典》、《个人信息保护法》以及以及

《个人信息安全规范》外，还有在本章开头所提及的《网络安全法》，上述规范皆提及生物识别信息，但可以发现但在对生物识别信息的称呼上有着略微的差异，前三者都采用了“生物识别信息”的称呼，而最早颁布的《网络安全法》采用的是“个人生物识别信息”的称呼更加强调了生物识别信息的主体性。如上文所述，在正在审核的《生物特征识别信息的保护要求（征求意见稿）》中，关于生物识别信息的称呼则分别采用了“生物特征识别信息”以及“生物特征识别数据”，在同一份规范性文件中出现了两个不同的称呼，前者注重的是生物识别信息的特征性即生物识别信息的不可更改性、高度人身依附性，而生物识别特征数据除了着重生物识别信息的特征性外，还关注生物识别信息的载体形式，正如前面所述，生物识别信息的产生，离不开生物识别技术的处理，而经过处理以后所形成的形式即是数据，因此生物特征识别数据强调的是信息载体的形式。虽然有不同的法律表述，但表述所蕴含的客体是相一致的，即生物识别信息，但由于缺乏明确的法律上的概念，导致各项法规之间由于侧重点的不同而采取了不同的表述形式，这样就不利于体现法律的一致性。⁹⁰

明确生物识别信息的法律概念有助于明确生物识别信息的范围与类别，随着生物识别技术的发展，越来越多与人身有关的特征被技术处理识别成为生物识别信息，行为特征识别信息由以前的签名、声纹、脚印慢慢发展到如今的步态特征识别信息，而生理特征识别信息由以前的指纹、肖像逐步发展到现在的指静脉、虹膜、视网膜等等，越来越多的人体特征被作为识别身份的方式之一。但上述规范我们可以看出，有的规范并没有列举出生物识别信息的范围或这类别，只有《生物特征识别信息的保护要求（征求意见稿）》以及《个人信息安全规范》中进行了相应的规定。《个人信息保护法》针对敏感信息的处理规则，规定了相应的引证条款，其规定信息处理者处理个人敏感信息是否应当获得行政许可或则者受到限制，有其他的法律行政法规有所规定的，依照其规定。⁹¹因此对生物识别信息作为个人敏感信息的一类其内涵和外延可以通过引证上述两份部门规范性文件。这两份规范性文件均采用不完全列举式的方式，列举了生物识别信息的范围，在明确生物识别信息范围的同时，也为未来新兴的生物识别信息留下了保护的空间。但问题是，前者仍在审核中并未生效，而后者作为一份部门规范性文件的国家标准，其并

90. 曾昌：“分离困境与整合路径：大数据时代下个人生物识别信息保护制度之完善”，《云南社会科学》，<https://kns.cnki.net/kcms/detail/53.1001.C.20210831.1730.030.html>，2021年9月2日，第117页。

91. 《个人信息保护法》第三十二条：法律、行政法规对处理敏感个人信息规定应当取得相关行政许可或者作出其他限制的，从其规定。

没有强制性的法律效力，效力层次位阶较低，宣示效果不足，无法为企业制定信息处理规则起到预示作用，并不能满足法律规制的效果。因此生物识别信息法律概念的模糊，是目前我国生物识别信息民法保护的困境之一。

二、未区分保护生物识别信息

《个人信息保护法》规定信息处理者对个人信息负有分类保护的义务，而《民法典》与《个人信息保护法》也按照不同的标准对个人信息进行区分，前者按照信息的私密性进行区分，将属于私密信息的个人信息纳入隐私权规范保护范围内，而后者则是按照个人信息的敏感程度进行划分，对敏感个人信息采取特殊的处理规则。由此可以看出，对个人信息进行分类分级保护的理念是蕴含在我们的立法精神之中。将生物识别信息纳入敏感个人信息当中，可以看出立法机构对概括性地对生物识别信息进行了区分保护。但纵观《个人信息保护法》敏感个人信息处理规则这一节，只有五条条文，除了前文所述的三十三条是引证条款外，大部分是对敏感信息的界定，比如敏感信息的内涵和范围。而真正与敏感信息的处理规则相关的只有处理个人敏感信息的单独同意规则以及告知必要性和影响规则。

而正如我们所一直强调的生物识别信息具有其特殊性，作为网络时代的数字身份，不可更改性、稳定性以及高度的人身依附性是其作为身份识别手段的重要优势，可识别性是生物识别信息的特性，也是生物识别信息的目的。因此相对于《个人信息保护法》中所列举的敏感信息，比如宗教信仰、金融账户、医疗健康、行踪轨迹等，生物识别信息作为敏感信息其更为突出的是可识别性的作用，“生物识别信息”的唯一价值性即在于对特定个人的识别性与链接性。⁹²相对于上述的敏感信息，由于生物识别信息的不可变更性，“变更”、“删除”等等信息主体所享有的权能手段无法起到保护生物识别信息的作用，而去标识化的处理手段则抹杀了生物识别信息的作用，让生物识别信息不再存有价值。综上，《个人信息保护法》所赋予信息主体查阅、更改以及删除的权利，的确增强信息主体对生物识别信息的支配与控制，但部分权利对于保护生物识别信息，并没有起到很好的效果。从权利的目的出发更改补充权是当个人信息出现记载错误是，信息主体请求信息处理者更正的一种补救措施，而生物识别信息是通过人体特征识别而生

92. 曾昌，前注[90]，第117页。

成的,一般情况下其并不会出现错误,出现错误的更多是与生物识别信息相结合的其他个人信息。从生物识别信息的特点出发,生物识别信息是不可更改的,一个人不能有两副面孔,除非其作出物理性的手术,自然人不可能用另一同一类别的生物识别信息进行替换,只能用不同类别之间的生物识别信息进行替换更改,向其他的敏感个人信息比如金融账户、身份证信息等可以通过补办、挂失以及更换保护方式等等方式对已经泄露或者遗漏的信息进行补救,并且仍可继续适用相应的敏感个人信息,而生物识别信息如果发生信息泄露的情况只能通过删除解决。因此不可更改性导致泄露后的无法追索、无法索回以及无法更改的后果,就要求了对于生物识别信息来说,需要更为严格的处理规则以及保护规则。

相对于立法机关,司法机关其实认识到了生物识别信息相应的特殊性,其在《个人信息保护法》出台以前业已颁布了关于处理人脸识别信息纠纷的司法解释,虽然最高法明确人脸识别信息属于生物识别信息,但是针对人脸识别信息所作出的相对应的司法解释能否推定适用于所有生物识别信息并没有给予明确的规定。因此虽然对生物识别信息作出了一个初步的分类保护规则,但目前的处理规则并没有针对生物识别信息的特性作出相应的规定,虽然有相对应的国家标准,但国家标准终究是一份没有强制效力的部门规范性文件,效力层级低的他并不能起到很好的法律保护的作用。另外在我国立法语义中,生物识别信息是被视为一个整体予以表达,但是值得明确的是生物识别信息是多种单一类别生物识别信息的集合,按照我国目前对个人信息分类的两种标准敏感性与私密性标准来看,每一类别的生物识别信息属于敏感信息,但是否属于私密信息需进行区分,目前仅仅通过敏感信息的处理归责对生物识别信息的处理行为进行规制保护并不全面。

三、生物识别信息的侵权救济制度存在疏漏

虽然《个人信息保护法》规定了过错推定的归责原则,但是不分场景,不分信息类别一味地适用过错推定原则,并不能很好地保护生物识别信息。过错推定的归责原则,意味着信息处理者需要证明自身无过错,才可以免责,通过证明责任的倒置,减轻信息主体的证明负担,降低信息主体的维权成本。但是这并没有很好地解决生物识别信息侵权中所存在的“证据偏在”的问题,信息处理者可以轻易地拿出其已经采取符合法律规定的保护措施的证据。但是生物识别信息具有不可更改、无法溯回的特性,作为网络时

代数字身份的核心，生物识别信息一旦泄露就意味着其生物识别信息退出身份识别的范畴，同样的因为其高度的人身依附性，生物识别信息是人格尊严与人格自由在生物识别信息的具现，因此其损害的不可复原要求其具有更严格的保护措施。泄露个人信息的行为是常见的个人信息侵权行为，笔者认为信息泄露也是对生物识别信息危害最大的行为，生物识别信息作为目前常见的锁控方式之一，与自然人的金融账户息息相关，通过对生物识别信息的逆向解码，甚至能还原生物特征的图像。如前文提到的利用他人人脸识别信息解锁支付宝账号盗窃财务的案子，因此对于生物识别信息应当重点规制其信息泄露的行为。实施生物识别信息的泄露行为的行为主体存在着两类人，一类是信息处理者或者信息控制者，信息处理者基于特定的目的收集信息主体的生物识别信息，而生物识别信息的载体是数据，在大数据时代下，数据已经成为一种重要的生产资料，蕴含巨大的财产价值，因此信息处理者有着强烈的侵犯生物识别信息的动机。而第二种则是第三人通过漏洞，或者攻击信息处理者的系统获取他人生物识别信息的泄露行为，在这种情境之下，信息处理者只要证明自己采取了必要的保护措施或者漏洞是无法预见的即可免责，在这种情形下，生物识别信息主体只能向实施侵权行为第三人进行追偿，但是现今社会，区块链技术的兴起，让侵权行为人以“比特币”为支付方式在暗网进行交易，信息主体的技术能力，无法很好地对侵权行为进行溯源，更遑论确定侵权行为人的真实身份。因此采取过错推定的归责原则并不能够完全起到保护信息主体生物识别信息的效果，不利于信息主体的侵权救济。

在我国侵权责任的承担方式有停止侵害、排除妨害、消除危险、赔礼道歉、消除影响、恢复名誉以及损害赔偿。停止侵害、排除妨害、消除危险。停止侵害、排除妨害、消除危险是一种绝对权的请求权，从属于属于绝对权的人格权，而正如我们所说生物识别信息作为一种民事利益并未上升为一项权利，因此上述责任承担方式则通过在《民法典》以及《个人信息保护法》中赋予信息主体删除权、更正补充等相应的权能。而由于生物识别信息的特殊性，其一旦泄露就意味着生物识别信息无法继续维持其网络数字身份只能采取删除处理，因此恢复原状的责任承担方式并不能很好地保护生物识别信息，因此损害赔偿是一种侵犯生物识别信息的主要责任承担方式。损害赔偿是损害赔偿作为一种侵权责任在损害赔偿的认定上，但是针对程序性违法行为能否适用损害赔偿制度予以救济，法律并没有明确的规定。如前文所述，生物识别信息并不属于一项绝对权利，不能适用“权利被侵害即存在损害”规则，但被泄露的生物识别信息属于敏感

个人信息，发生下游损害的风险相当明显。⁹³因此即使人脸识别的司法解释以及《个人信息保护法》都认可处理生物识别信息过程中的“程序性违法行为”属于侵权法概念上的侵权行为，但对于程序性违法行为能否适用损害赔偿的民事责任承担方式，无论是人脸识别信息的司法解释还是《个人信息保护法》都没有明确的规定。根据司法解释中明确信息处理中程序性违法行为属于侵害自然人人格权益的行为，⁹⁴并且侵害人格权益造成财产损失的自然可以主张损害赔偿，而财产损失的范围包括为制止侵权行为所支付的合理开支，即自然人进行调查取证的合理费用以及合理的律师费。⁹⁵而《个人信息保护法》也规定损害赔偿按照信息主体受到的损失或者信息处理者因此获得的利益确定，如果难以确定的，则根据实际情况确定相应数额。⁹⁶另外对于精神损害，民法典规定拥有人身权益权利人可以向侵权行为人请求承担精神损害的赔偿责任，但是前置条件是权利人因行为人的行为遭受严重的精神损害。由此可见立法上对损害赔偿的认定给予了法院很高程度的自由裁量权。结合司法实践的情况我们可以看到，法院认定损害赔偿仍需信息主体对损害的事实予以证明，而生物识别信息的损害具有潜在性、抽象性以及无形性，当信息泄露没有造成下游损害时，信息主体往往会因为无法证明损害的存在或者被认为损害轻微而无法得到合适的救济。

93. 谢鸿飞：“个人信息泄露侵权责任构成中的‘损害’——兼论风险社会中损害的观念化”，《国家检察官学院学报》，2021年第5期，第31页。

94. 《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》第二条。

95. 《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》第八条。

96. 《个人信息保护法》第六十九条。

第三章 生物识别信息民事保护的比较法考察

国外针对生物识别信息的立法保护起步较早，如前文所提到的美国的伊利诺伊州《生物识别隐私保护法案》以及欧盟《通用数据保护条例》皆是域外国家政治体对生物识别信息的保护问题而出台法律。这两部法律代表的是如今世界上两种对生物识别信息的保护模式，分别是专门保护模式以及综合保护模式。

第一节 生物识别信息专门保护模式

生物识别信息的专门保护模式是指立法机关针对生物识别信息出台专门的保护法案，在法案中规定信息处理者对生物识别信息的处理规则、生物识别信息主体所享有的权利以及权利救济的途径。而美国是专门保护模式的代表国家。

一、美国生物识别信息的民事立法保护

美国是一个联邦制的国家，除了国家议会拥有立法权，每个州可以针对自己州的情况制定适应州情的法律。这就导致了美国在隐私和数据保护方面的立法长期保持着碎片化特征，即各行各业、各领域，以及各州分别针对特定场景下的消费者隐私保护各自出台立法，这种分散式立法虽然具有更强的灵活性，但在形式上也过于松散。⁹⁷而生物识别信息的立法则更为明显，目前美国在联邦层面中没有制定关于生物识别信息的法案，因此对生物识别信息的保护仍然依赖于各州的州立法。伊利诺伊州的 BIPA、德克萨斯州的《生物特征符获取或使用法》（Capture or Use of Biometric Identifier Act 以下简称“CUBI”）、华盛顿州的《生物识别隐私法》（Washington Biometric Privacy Act，以下简称“WBPA”）以及加州的《加利福尼亚州消费者隐私法案》（以下简称 CCPA）则是这一立法模式下的典型代表。

BIPA 是美国最早出台的关于生物识别信息保护的法案，而 CUBI 和 WBPA 也是在 BIPA 出台后，其他州根据各州自身情况从，参照 BIPA 所设立的关于生物识别信息的保

97. 周雪峰、蔡雄山主编：《网络空间法治化的全球视野与中国实践》，北京：法律出版社，2019 年版，第 19 页。

护法案,因此三者之间在立法章节体系上有着相似的地方,皆是从生物识别信息的定义、生物识别信息的处理规则以及权利救济三个方面进行规定。三部法案皆对生物识别信息的定义和范围作出了规定 BIPA 和 WBPA 在生物识别信息的定义和范围是一致的,把照片、视频、录音以及用于医疗的生物识别信息排除出生物识别标识符的范围,⁹⁸ 而 CUBI 则明确指出生物识别信息是指视网膜或虹膜扫描、指纹、声纹或者掌纹以及面部特征的记录,但将应用于金融主体收集的生物识别信息排除法案范围。⁹⁹在信息处理规则上,信息主体的知情同意是信息处理主体收集生物识别信息和披露生物识别信息的基础,BIPA 要求获得知情同意的形式为书面,但并未规定书面同意必须为纸质。信息处理者对生物识别信息的披露除了前文所说的知情同意,还包括为了信息主体的金融交易的信息披露、立法规定的披露以及司法上的披露。另外信息主体对生物识别信息的处理,三个法案都要求了禁止获利的原则,也就是信息处理者不得对收集的生物识别信息进行商业上的获利行为。而在披露规则上,CUBI、WBPA 也采用与 BIPA 一样的披露规则,但是 WBPA 将披露的范围进行了扩大。¹⁰⁰另外 BIPA、CUBI 和 WBPA 都规定了信息处理主体要制定书面保留政策、保管时限以及目的用尽时信息处理主体负有删除生物识别信息的义务。在权利救济上,三部法律都规定了侵权损害赔偿诉讼的救济路径,并且对与损害赔偿的数额作出了最高额的限定,并且信息主体可以通过禁止令的方式予以请求救济。¹⁰¹但是对于诉讼的适格主体,BIPA 与 CUBI 和 WBPA 也不一样,BIPA 允许私人提起侵权诉讼,也允许州总检察长提起诉权,但 CUBI 与 WBPA 并不允许私人提起相应的诉讼,只有州检察长才享有诉权。¹⁰²

除了上述的三分专门针对生物识别信息的法案,美国的专门立法模式的生物识别信息保护还有另一种路径,就是针对某一特定行业的个人信息予以保护,并将生物识别信息纳入个人信息的之中给予保护,比如 CCPA 就是这一类别的专门立法模式下的法案。CCPA 与下文将会展开论述的综合立法模式也有所不同,CCPA 规制的范围比综合立法模式下的法律所规制的范围要小,仅针对消费商业行为中的处理个人信息的行为进行规制。CCPA 规定了知情同意原则、合乎目的原则以及信息处理者对消费者的目的类别披

98. Washington Revised Code §19.375.010(2017).

99. Texas Business and Commerce Code §503.001(a) (e) (2009).

100. Washington Revised Code §19.375.020 (3)(2017).

101. Illinois Compiled Statutes Chapter 740§14/20(2008).

102. Texas Business and Commerce Code §503.001 (d) (2009); Washington Revised Code §19.86.140(2017).

露义务。¹⁰³另外还规定了消费者享有的删除权以及行使删除权的例外情形。CCPA 并不禁止利用个人信息的商业获利，但是未满十六周岁的信息主体其个人信息不允许买卖，售卖个人信息的 CCPA 赋予了信息主体退出的权利，防止自身个人信息被买卖。¹⁰⁴在权利救济上，与 BIPA 一样允许消费者行使诉权，或者由总检察长提起民事诉讼，并规定了法定损害赔偿金的数额范围，让消费者决定是选择法定损害赔偿金还是选择以实际损害为标准的损害赔偿金金额。但是消费者提起诉讼有着限制，一是诉前需通知企业整改只有针对实际发生得损害提起得诉讼才可避免通知企业得义务，二是总检察长诉讼前置的模式，消费者在向法院起诉之前，应当通知加州总检察长，总检察长在接受通知后的法定时间内，应当作出相应的决定，当总检察长六个月内没有起诉，消费者才可以采取诉权；当总检察长在法定时间内，决定不起诉企业或者避免起诉相应的企业时，可以告知消费者继续起诉；又或者让消费者不起诉相关企业。当总检察长介入相关纠纷时，决定以其名义提起民事诉讼时，相关企业所承担的民事责任与消费者自行起诉所承担的民事责任相比有所升格，企业或因其每次违规行为，需承担高达 7500 美元的民事罚款。CCPA 虽然对企业的信息处理规则、侵权救济途径以及生物识别信息的内涵类别作出明确规定，但未对个人信息进行分类保护，未出台专门条文保护生物识别信息。针对 CCPA 这一情况加州政府颁布了《加州隐私权法案》。在该法案中明确对个人信息进行分类将生物识别信息分类为个人敏感信息中，并规定第三方平台使用个人敏感信息的应当告知消费者使用的目的、种类以及是否出售分享，消费者有权对敏感信息的使用范围进行严格的限定。¹⁰⁵

二、美国生物识别信息的民事司法保护

上述法案中，对生物识别信息作出专门立法保护的三份法案的条文数量较少，而 CCPA 和《加州隐私权法案》的条文数量较多，语义详细。虽然有着专门的立法文件保护，但在司法实践中，相关条文的适用还是会产生一定的问题。结合对美国关于生物识别信息案例的查阅，笔者发现在生物识别信息的侵权案件中，争议焦点主要有两个，一个是对生物识别信息的范围认定，第二个则是对侵犯生物识别信息的损害结果的认定。

103. California Civil Code§1798.140(b)(2020).

104. California Civil Code§1798.120(d)(2020).

105. 张继红、文露：“美国《加州隐私权法案》评述”，《中国信息安全》，2021 年第 3 期，第 75-76 页。

（一）生物识别信息的范围认定

BIPA 明确将照片和视频排除出生物识别标识符，而生物识别信息是通过生物识别标识符而产生的，因此信息处理者通过对照片、视频等非生物识别标识符进行技术化处理所获得的面部特征数据是否属于生物识别信息的范围存在着争议，而在所探究的关于美国生物识别信息纠纷的案例中，被告科技公司均以照片、视频不属于生物识别标识符为由，主张其通过技术处理从视频图片所截取的面部特征数据不属于生物识别信息，进行抗辩，要求法院驳回诉讼。但是在 *Rivera v. Google Inc* 一案中，法院对此作出了解释，法院认为法案中并没有限制生物识别标识符的获取方式，无论生物识别标识符转换成哪种形式，只要其转换后的信息可用于个人身份识别，即属于 BIPA 范围的值得保护的生物识别信息。法院指出“生物特征符”和“生物识别信息”区分的意义在于，前者是一套可用于识别自然人的基于生物特征的测量办法，是生物特征测量的集合，后者是将这些测量转换成不同的可用的形式；后者是将这些测量转换成不同的可用的形式；前者只是用于识别一个人的、特定的、基于生物学的测量，并不涉及测量是如何进行的，而后者确保收集者不能通过将生物特征符转换成某种其他形式来规避法律。¹⁰⁶而法院这一说理部份也影响了后续法院对生物识别标识符的理解，比如 *Vance v. Amazon.com Inc.* 明确指出生物识别标识符不包括照片，但是面部特征模板本质上是通过生物特征产生，属于生物识别信息，生物识别标识符是所列举的范围是对特定物质进行扫描测量的行为而不是物质媒介；¹⁰⁷而 *Hazlitt v. Apple Inc* 一案中将生物识别标识符解释为一套可用于识别自然人的基于生物特征的测量办法”，对照片进行面部扫描所获取的人脸模板属于 BIPA 的保护范围；*In re Facebook Biometric info. Privacy Litigation* 一案，法院认为生物识别标识符所排除的照片是指纸质照片，不包括电子形式的照片，所以照片数据属于生物识别标识符。¹⁰⁸因此通过法院一系列的以案释法，将生物识别标识符所排除的范围进行了确定，生物识别标识符所排除的照片、视频以及录音是指以实体物质形式存在的物质。生物识别标识符并非一种具体的物质，而是一种测量行为，只要能转换成数字形式并以此转换为相应的生物识别模板，那么无论是否被排除出生物识别标识符，其最终形成的生

106. *Rivera v. Google Inc.*, 238 F. Supp. 3d 1093-1095 (N.D. Ill. 2017); *Rivera v. Google Inc.*, 238 F. Supp. 3d 1096 (N.D. Ill. 2017). 转引自陆海娜、赵赓：“个人生物识别信息商业利用的法律规制：美国州立法经验的比较与反思”，《人权研究》，2021年第2期，第89页。

107. *Vance v. Amazon.com Inc.*, 525 F. Supp.3d 1301 (2021).

108. *In Re Facebook biometric information privacy litigation*, 326 F.R.D. 535(2018).

物识别模板也属于生物识别信息。

（二）侵犯生物识别信息的损害结果范围认定

另一个争议焦点就是对损害结果的认定，对损害结果的认定在美国的司法实践中也是存在着一定争议。在美国，要提起诉讼必须要满足美国联邦宪法第3条规定的起诉资格(standing to sue)的基本要求：（1）其遭受了“事实上的损害”(injury-in)；（2）该损害源于被告的行为；（3）该损害有通过司法裁判进行救济的可能性。¹⁰⁹因此在司法实践中，也导致美国法院对生物识别信息侵权损害的认定产生不一样的判决，被害人是否需要证明实际损害的存在是认定。

1. 被害人需要承担具体损害结果证明责任的判决

Spokeo Inc. V. Robins 一案虽然不属于涉及生物识别信息的纠纷，但是其属于个人信息纠纷，因此在对侵犯信息纠纷案件中，该案判决对损害结果的相关认定成为了美国部份案例的判决依据。在 *Spokeo Inc. V. Robins* 案中，美国最高法院认为损害是具体的客观真实存在的，“具体”不要求一定有形，无形的损害(intangible harm)也可能是具体的，但是未发生的无形损害应该由国会进行确定，因此本案中单纯的程序性违法不能认为是具体的，另外该案中的托马斯大法官对不同性质权利损害的具体性要求作出了区分，其认为原告如果维护自身私人权利时，其损害的具体性质要求并不严苛，而原告试图维护联邦法规中体现的公共权利，必须证明对该公共权利的侵犯给他造成了与一般人群不同的具体个人伤害。¹¹⁰*Spokeo* 案确立了损害具体性的标准，也要求了被害人承担损害结果具体性的证明责任，而这一判决也影响了后续部份美国生物识别侵权纠纷中，比如前文所述的 *Rivera v. Google Inc* 一案，最终结果是法院认为并不存在具体的损害，驳回了原告的损害赔偿请求。

2. 被害人无需承担具体损害结果的判决

Spokeo 案虽然明确了个人信息侵权纠纷损害结果具体性的要求，但是对具体性的内涵却没有明确的规定。在 *Bryant v. Compass Group USA Inc* 一案中，审判法官认可损害具体性标准，但是对损害具体性的内涵有着与 *Spokeo* 案的法官有着不同的理解。法院就认为程序性违法的行为所造成的损害是具体的，法院在说理部份提出信息处理者在收

109. 田野：“风险作为损害：大数据时代侵权‘损害’概念的革新”，《政治与法律》，2021年第10期，第26-27页。

110. *Spokeo, Inc. v. Robins*, 136 S.Ct. 1540(2019).

集他人生物识别信息时，并没有披露书面的保留政策，这使得消费者没有机会考虑这种收集和使用的条款是否可以接受，考虑随之而来的风险，本质上造成了一种具体的伤害，即消费者丧失了对其生物特征信息的收集、存储和使用做出知情决定的能力和能力。¹¹¹

另外在 *Figueroa v. Kronos Incorporated* 一案中，法院明确了信息损害的概念，其认为法律规定信息处理者有公示义务，如果违反公示义务隐瞒相关信息告知的，属于信息损害，信息损害是具体的，因此信息处理者没有披露信息主体所享有法定权利的信息，则未披露会造成具体的损害。但是如果被告只是不完整或在技术上有缺陷的披露，则不会造成损害。¹¹²因此原告如果能证明信息处理者违反了相应的公示义务，原告即无需证明损害的具体性。而被告如果要免责则需要对违反公示义务的行为承担证明责任。

除了对损害的具体性标准作出相应解释，有的法院在面对生物识别信息的损害赔偿请求，会创设性地引入行为自身可诉性侵权制度，对信息主体所享有的信息权益进行解释，从而免除信息主体对事实损害的证明义务，从而支持信息主体的损害赔偿请求。比如 *Rosenbach v. Six Flags* 一案，伊利诺伊州最高法院认为生物识别标识符是数字世界的核心身份，现存的技术下批发收集和存储个人独特生物识别标识符已成为现实，如果损坏或误用，这些标识符无法更改，一旦一个人的生物识别码或生物识别信息遭到破坏，难以提供有意义的追索权的支持，因此私人实体在没有遵循 BIPA 的知情同意原则时，未经生物识别标识符主体同意，私密地收集保管其生物识别信息的行为构成侵犯、损害或剥夺生物识别标识符或生物识别信息受到侵犯的任何个人或客户的法定权利，遭受侵权的生物识别标识符主体无需证明其遭受的损害结果。¹¹³又比如前文提到的 *In re Facebook Biometric info. Privacy Litigation* 一案，加州法院认为生物识别信息纳入隐私权范畴其理论基础之一在于隐私法中索偿的可操作性传统，让数据的控制支配，免遭披露或滥用风险的制约，信息处理者违反 BIPA 的通知与同意原则，无需受害者证明实际损害的存在。由此可见，除了对损害的具体性标准作出解释的保护路径外，创设性地引入行为自身可诉性制度也是对信息主体的一种保护路径，行为自身可诉侵权制度来源于英美法国家，是指原告或者受害人只需向法院证明被告实施了相关侵权行为，而无需进一步具体证明自己因被告的行为所遭受的损害，即可要求被告承担侵权责任的侵权行为类型，而一般能适用行为自身可诉性侵权制度的侵权类型包括暴力威胁、暴力侵犯、错误

111. *Bryant v. Compass Group USA Inc.*, 958 F.3d 617 (2020).

112. *Figueroa v. Kronos Incorporated*, 454 F.Supp.3d 772 (2020).

113. *Rosenbach v. Six Flags*, 2019 IL 123186. 转引自陆海娜、赵赓，前注[106]，第 91 页。

拘禁、侵犯土地、侵犯动产以及损害名誉等六种类型，而侵犯信息权益并不包括其中，¹¹⁴因此上述案例中，法院将信息处理者违反程序的义务，即可视为损害的裁判要旨是行为自身可诉侵权制度在侵犯生物识别信息领域的创设性运用。

第二节 生物识别信息综合立法保护模式

对生物识别信息采取综合立法的保护，是指设立个人信息保护的综合性法律，将不同种类、级别、性质的个人信息纳入统一的个人信息保护法之下，将行政、民事以及刑事法律的保护措施集为一法。¹¹⁵这一保护模式是世界的主流保护模式，许多国家地区或者政治体皆采用这一保护模式比如欧盟，我国的香港、澳门以及台湾地区等等皆是采用这一保护模式对生物识别信息纳入他们现行的法律体系中，对生物识别信息予以保护。因为采用综合立法的保护模式，欧盟、香港、澳门以及台湾地区对生物识别信息的法律保护有着相似的特点，通过对上述地区的立法梳理，综合保护模式对生物识别信息的保护可以划分为以下几个方面：列举生物识别信息的范围、规定生物识别信息类别与处理规则以及规定生物识别信息的侵权救济措施。

一、列举生物识别信息的范围

欧盟对生物识别信息范围的确定是通过定义+列举的方式。如本文第一章所述，欧盟的《通用数据保护条例》对生物识别信息的定义作出规定强调生物识别信息的“技术处理性”以及“特征性”，并通过列举的方式，列举出了人脸图像数据与指纹数据两种生物识别信息类型，并将肖像与生物识别数据中的图像数据进行区分。

与欧盟相比，我国香港、澳门以及台湾地区也出台了相应的综合性个人信息保护法，但在生物识别信息的范围确定上，香港、澳门与台湾地区并没有像欧盟一般针对生物识别信息，额外采取“定义+列举”的方式确定生物识别信息的定义与范围。而是仅仅明确个人信息的定义，并采取不完全列举的方式，罗列个人信息的范围，把某一类别的生

114. 胡雪梅：“英美侵权法行为‘自身可诉’侵权制度及其合理借鉴——以我国侵权责任法的完善为中心”，《现代法学》，2011年第1期，第143-144页。

115. 付微明：“个人生物识别信息的立法保护模式与中国选择”，《华东政法大学学报》，2019年第6期，第80页。

物识别信息罗列进去。¹¹⁶这种不明确生物识别信息定义，仅仅罗列某一类别生物识别信息作为个人信息范围的做法虽然在某种程度上明确了生物识别信息受到相应的法律保护，但是技术的发展会导致越来越多的生物特征被应用于识别个体身份，也就意味着越来越多的生物识别信息会出现在大众视野，而生物识别信息定义的缺失，会导致人们对某一类新型生物识别信息是否受到法律保护，该采取何种处置措施感到疑惑，这也导致了法律的导向作用的缺位。而香港地区和澳门地区为了弥补这一立法缺位，只能通过颁布行政指导性文件，通过行政指导性文件，对生物识别信息的定义进行明确，比如香港地区就另行发布了《收集及使用生物辨识资料指引》将生物识别信息称呼为生物辨识资料，认为生物识别信息与人有关，当跟数据库的其他个人信息相结合，可发挥识别性，因此生物识别信息属于《个人资料（私隐）条例》的保护范围；¹¹⁷而澳门针对不同类别的生物识别信息出台了三份指引分别是《关于应用面型特征资料考勤系统的查询》、《使用使用指纹/掌型考勤设备的问题》以及《有关采用指纹/掌形以外识别生物特征技术之考勤设备的问题》明确指出为考勤而收集的生物识别信息属于澳门《个人资料保护法》中的个人资料，处理上述生物识别资料受到《个人资料保护法》的规制。

二、规定生物识别信息类别与处理规则

综合立法的保护模式的保护重点在于个人信息，因此除了生物识别信息，往往还会列举其他的个人信息，而采用综合立法保护模式的政治体和地区往往会从按照敏感性或者特殊性的标准对个人信息进行分类保护，将个人信息划分为一般个人信息与特殊/敏感类别个人信息，为特殊/敏感类别个人信息设立相对应的处置规则，而采用综合立法模式的欧盟、澳门地区以及台湾地区皆是采用这种分类方法为生物识别信息设定特殊的处置规则。而针对特殊类别的个人信息，所采用的处理原则是一般禁止处理原则，只有在特殊情况下才可以对特殊类别的个人信息进行处理，对比欧盟、澳门以及台湾地区所规定的例外情况，可以总结出可以处理敏感类别个人信息的情形主要有以下几个方面：（1）获得信息主体明确的知情同意；（2）信息处理是为了保障信息主体自身或他人利益的必要手段；（3）当事人业已公开的信息；（4）因为司法活动上的需要而进行处理的敏

116. 《香港个人资料（私隐）条例》第2条；澳门《个人资料保护法》第四条。

117. 香港个人资料私隐专员公署：《收集及使用生物辨识资料指引》，https://www.pcpd.org.hk/tc_chi/resources_centre/publications/files/GN_biometric_c.pdf，2021年8月21日，第1页。

感个人信息；（5）基于重大公共利益，为了完成相应的统计；（6）法律规定的需要处理的或者为了协助公务机关履行法定职务义务而处理的。

而香港地区对信息的区分保护并没有像上述综合立法模式的政治体地区一样按照敏感性程度或者特殊性的程度对个人信息进行分类保护。其更强调的是对个人信息场景的应用适用途径进行区分，反而是针对个人信息的使用途径进行区分，香港针对商业促销中对个人资料的使用采取了特别处理规范，除了社会福利署营办的社会服务、医管局或卫生署提供的医护服务外，其他在直接促销中使用个人资料的都受到特别规范的规制。

除了对生物识别信息所属于的个人敏感信息设置特殊的处理规则之外，综合立法模式也会赋予信息主体对其个人信息享有部份权能，以增强他们对自身个人信息的控制支配能力，并且规定信息处理者所负有的保密义务以及规定相应的保存时限。因此无论是欧盟还是我国的香港、澳门以及台湾地区，都会赋予信息主体对其个人信息享有访问、更正、删除、限制处理、携带、反对以及同意撤回等权能，而当信息主体行使上述权能之时，信息处理者还附有协助的义务。

三、规定生物识别信息的侵权救济措施

综合立法保护模式下所制定的相关个人信息保护法律，是公法与私法的相结合，在针对生物识别信息的侵权救济措施上，既有由公权力机关进行主导的救济措施，也有由信息主体自行救济的民事措施。因此欧盟、香港地区、澳门地区以及台湾地区都会针对个人信息保护设立独立的信息监管机构。

欧盟的《通用数据保护条例》允许信息主体自行提起诉讼，可以针对信息监管机构以及信息处理者提起诉讼，信息监管机构对于除了法庭司法活动中进行的信息处理操作以外的一切信息处理行为拥有监督监管的职权，当信息监管机构不履行信息主体申诉，或在法定时间内没告知申诉时间或进展，信息主体即可针对监管机构获得司法救济。而由于 GDPR 赋予监管机构行政罚款的权力，因此信息主体针对监管机构提起的诉讼，本质上是针对行政机构不作为提起的行政诉讼，¹¹⁸而针对信息处理机构的诉讼，则是属

118. 《通用数据保护条例》第 78 条。

于民事诉讼。¹¹⁹而香港、澳门、台湾地区也规定了信息主体对侵犯个人信息的行为，可以提起相应的民事诉讼以追求相应的赔偿。

在归责原则的规定上，欧盟、香港地区与澳门地区皆采用的是过错推定的归责原则，¹²⁰而台湾地区在归责原则上则是采用二元制，其将信息处理主体区分为公务机关与非公务机关，针对公务机关违反“个人资料保护法规定”致使信息主体的个人信息被不法收集处理利用或者其他侵害当事人权利所造成的损害，只有损害的原因是不可抗力造成的，才能免责，否则应当承担赔偿责任，这一规定，类似于民事侵权的无过错责任，¹²¹而非公务机关则是适用过错推定的归责原则。

第三节 生物识别信息保护模式比较法评析

从立法上形式，无论是专门保护模式还是综合保护模式，在对生物识别信息的保护上有着共同保护逻辑，即从保护的范围、信息处理者的行为义务、信息主体所享有的权利以及权利救济的途径出发，有着共同的立法保护背景，即生物识别技术被大规模应用于各种社会场景，人民对自身生物识别信息被探知的状况感觉到日渐担忧。在对生物识别信息的保护上，无论是专门保护模式还是综合保护模式，皆意识到生物识别信息的重要性，明确了生物识别信息现今网络社会的数字身份，属于敏感的个人信息，明确了生物识别信息的生成离不开技术化处理，而对生物识别信息的处理，都有着共同的处理原则，即使“禁止处理”、“明示的知情同意”以及“法律规定所必须处理”三个共同的处理原则。救济途径上，通过使用过错推定责任或者无过错责任，降低信息主体的证明负担。从保护的形式以及对生物识别信息概念的理解，专门立法模式与综合立法模式都有着相同的保护手段，从立法价值上看，生物识别信息对于人格权益保护的重要性以及特殊性，皆被认可。

虽然综合保护模式与专门保护模式对生物识别信息有着共同的保护逻辑，但是在具体内容上，两者仍然存在不同之处。专门模式可针对生物识别信息，实行专门性立法制定特殊的信息处理规则，对生物识别信息主体与信息主体者之间的权利义务关系可以制定针对性的法律规定，针对不同行业不同性质的信息处理者其可以制定不同的生物识

119. 《通用数据保护条例》第 79 条。

120. 《通用数据保护条例》第 82 条；《香港个人资料（私隐）条例》第 66 条；澳门《个人资料保护法》第十四条。

121. 台湾“个人资料保护法”第 28 条。

别信息处理义务，而这些优势是综合立法保护模式所不具备的。综合立法模式由于是对个人信息整体予以保护，其并不能对生物识别信息作出专门性的保护规定；专门立法模式有专门的法律概念群及对概念内涵的详细阐释、分解以及对特定主体，特定保护原则和限定条款与保护措施的规定等，都是综合保护模式所不具备。综合模式是对将个人信息作为一个整体纳入法律的保护法范围之内，然后在根据敏感程度对个人信息内部进行区分，设立敏感信息的处理规则，而生物识别信息也会受到敏感信息处理规则的保护，但是生物识别信息与其他敏感信息相比是具有特殊性的，为了法典的统一性，综合立法模式不再可能根据生物识别信息这一单一类别的生物识别信息进行专门规定。因此在对生物识别信息法律保护的专门性上并不如专门模式。但是综合模式也有着专门模式无法比拟的优势。专门模式保护方法保护措施单一，多是以民事侵权赔偿、民事违约赔偿以及民事诉讼为保护方式。而综合保护模式除了上述所提及的民事保护规范，其主要还是以行政法律保护方法和措施为主，并结合少量的刑事保护规范，令保护路径更有层次感，而综合保护模式会设立一个专门针对个人信息保护的行政机构，以保障个人信息相关保护规范的施行，以及作为信息主体请求救济的对象之一，这也导致了采用综合模式的国家关于生物识别信息的司法保护多是以公法上的纠纷为主。

立法上无论是综合模式还是专门模式，皆会在相关规范篇章的开头明确生物识别信息的内涵与定义，尽力确定生物识别信息的内涵与外延。如前文所述我国对生物识别信息的概念以及类别作出的规定的现行规范层次较低，而《民法典》与《个人信息保护法》皆未明确相关法律概念，所以应该学习两种立法保护模式对生物识别信息的概念与类别进行一个明确的规定。再者结合美国的司法实践，可以知悉，一个好的定义可以避免许多的纷争，前文所列举的美国审判案例中，对图像、视频采用技术手段测绘所形成的面部特征识别信息是否属于 BIPA 规定的生物识别信息存有争议。如前文所述，BIPA 认为的生物识别信息时通过对生物识别标识符进行测量获取等手段所形成的，该定义尽可能的把形成生物识别信息的范围囊括进来，同时为了跟肖像、声音等其他人格权益作区分，采取举反例的方式将部份‘载体排除出了生物识别标识符的范围，其中包括视频和照片。BIPA 的做法好处是明确了生物识别信息的内涵，确定了其外延边界的同时，也尽可能的囊括新技术的发展所涌现出来的生物识别信息。但是 BIPA 的设立是在 2008 年，而得益于网络的发展，生物识别技术已经可以通过数据爬虫等手段对网络上的照片进行抓取分析从而获取相应的生物识别信息，而很明显 BIPA 设立时并未预见网络技术

的发展，其次 BIPA 对生物识别信息所作出的定义陷入了以“抽象”解释“抽象”的困境，其并没有明确生物识别标识符的内涵，而仅仅通过列举的方式列明生物识别标识符的范围，会导致引起他人的认识偏差，并且也会发生不周延的情况，欧盟的《通用数据保护条例》所作出的关于生物识别信息的定义与之相比更具有科学性，明确了生物识别信息的性质与范围。在司法领域，美国法院并没有采用文义解释的解释办法，机械地适用法律条文，想当然地将对图片、视频所分析获取的人脸识别信息排除出生物识别信息的范围内。而是立足于目的解释、体系解释以及历史解释等解释方法，提出生物识别信息是对人体生物特征的测量所形成的产物，区分了生物特征载体与生物识别信息，且确定了生物特征载体经过技术化的处理可以转变为生物识别信息。

其次应该学习专门保护模式的立法价值，为生物识别信息设立专门规定，目前《个人信息保护法》中将生物识别信息纳入个人敏感信息，这是一项能加强生物识别信息保护力度的举措，但是个人敏感信息处理规则模糊，需要根据引证条款予以补充，而生物识别信息专门保护规范效力层级低，并不能发挥应有的功能。专门保护模式相比较于综合保护模式，虽然采纳该模式的国家较少，但是专门模式能够针对生物识别信息的特殊性作出特定的处理规则。具有指向性强，针对性强的特点。而综合模式，虽然能够以区分敏感信息的方式，对生物识别信息作出一些特殊的处理规则，但由于条文的篇幅、体例等要求，往往会采用提取公因式的方法，提炼出敏感信息的共性，以共同的规则进行处理，本质上是一种披上特殊外衣的概括性保护，而这也无法很好的对信息处理者的处理行为起到相应的法律导向作用，因此部份采取综合模式的国家或者地区往往会在综合性立法后，由他们设立的个人专门保护机构针对生物识别信息额外的出台相对应的规范性文件，比如前文所提的我国香港地区以及澳门地区均是采取了这一方式。因此在立法上我国可以学习专门保护模式，出台专门的保护规章，增强对生物识别信息的保护力度。

最后在侵权损害救济，美国虽然规定了最高实际损害赔偿数额制度以及法定最高限额赔偿制度，但是对于损害结果是否实质具体，以及损害结果的标准是什么并没有明确规定，就像前文所提及的在美国要提起诉讼，需要事实上的损害。而侵犯生物识别信息的损害多是无形的损害，这就导致了在司法实践上，美国在对损害事实的认定存在争议，但是美国部份法院通过对损害事实提出具体性标准，并且对具体性标准作出扩大化解释或者引入自身可诉侵权制度，让原告免于承担损害结果存在的证明责任。而对比我国的

司法实践,会发现对财产损害的认定标准较为宽松,却对精神损害赔偿的标准较为严苛,一定要原告证明遭受严重精神损害,但是在侵犯生物识别信息的案件中,由于人身依附性高,因此信息主体会遭受恐惧、不安以及紧张等情绪困扰,笔者认为一定程度上可以学习美国司法实践中的做法,对生物识别信息的损害结果的认定进行适当的放宽。

第四章 我国生物识别信息民法保护路径的完善

结合域外生物识别信息的民事规范以及司法案例与我国的立法与司法现状进行比较分析，笔者认为对生物识别信息民法保护的完善需要从明确生物识别信息的法律概念、生物识别信息的区分保护以及生物识别信息的侵权责任三个方面进行着手。

第一节 明确生物识别信息的法律概念

在规范层面，我国并非没有规定生物识别信息的内涵和外延，但是设定生物识别信息内涵与外延的规范，其大部分呈现出效力层次低，强制效力不足的缺陷。而且制定的规范呈现分散式立法的特点，在《网络安全法》实施以前对生物识别信息的规范保护偏向于单一保护，即只着重于某一类别的生物识别信息的保护，比如指纹识别信息、人脸识别信息等。而造成这些现状的原因之一即是因为未在法律层面上明确生物识别信息的法律概念，对生物识别信息没有一个全面的认识，导致在生物识别信息保护层面上出现偏重保护一类生物识别信息的情况出现。生物识别信息作为网络时代个人数字身份的核心，蕴含的是自然人自身的人格利益，而正如本文第一章所说数据是生物识别信息的载体，数据是生物识别信息呈现出财产利益外观的本源，而法律概念的模糊引起了生物识别信息权利性质的模糊，体现着作为本源属性的人格属性与数据载体财产属性的冲突。

法律概念是解决法律问题的核心工具，法律概念的明确与否直接关系着法律逻辑与保护路径的选择。¹²²明确生物识别信息的法律概念，首先应该统一生物识别信息的称呼，每个国家（地区）对生物识别信息的称呼有所不同，美国称其为生物识别信息，欧盟称为“数据”，而港澳台地区则称为“资料”。无论是“数据”还是“资料”其实均是对“Data”这一英文的单词所作出的不同的中文翻译，从英语语义的角度上以及信息科学的角度来说来说数据与资料为同一内涵，即指采用具有可识别性的蕴含内在意义的标识符对客观事物加以表示得到的标识符排列组合。而信息则是指数据或者资料经过处理后所提供的信息。可以说信息和数据之间的关系是内容与载体之间的关系，个人信息的表现方式可以是多种多样的，既可以表现为数据的形式，也可以表现为其他形式，因此个

122. 曾昌，前注[90]，第120页。

人信息的范畴大于个人数据的范畴。¹²³基于此我国在个人信息保护的立法过程中,采用了个人信息这一称呼,而生物识别信息作为个人信息的一类,自然而然地采用了“生物识别信息”这一称呼。即使采用了“信息说”,而生物识别信息的不同称呼也是围绕信息说来展开的,笔者认为对生物识别信息的称呼应该侧重其可识别性,可识别性是生物识别信息产生的目的,也是生物识别信息所需要发挥的作用,而“生物特征识别信息”、“个人生物识别信息”这两者虽然都体现了可识别性,但是其更侧重的分别是特征性和主体,但本人认为生物识别信息这一称呼更为恰当,首先可识别性蕴含着特征性的内涵,可识别的基础建立于生物特征,只有独一无二的生物特征才可用于识别,比如虹膜、指纹、基因等,而不具有独特性的生物性状、行为并不能作为识别的对象,比如肤色、身高体重等,因此在此种语义环境下,“生物识别信息”这一称呼实则包含了“特征性”。至于对信息主体的强调,笔者认为高度的人身依附性是生物识别信息的特征之一,也是其与其他个人信息最大的差别之一,只有自然人自身的生物特征,才能形成因此生物识别信息中生物二字已经点名了其主体属性,而无需再着重强调。虽然我国采取了“信息说”的称呼方式,但并非没有其他的称呼存在,正如前文所提到的《生物特征识别信息的保护要求(征求意见稿)》中,就采用了“生物特征识别数据”的称呼。正如前文所述数据与信息是载体与内容之间的关系,但对于生物识别信息来说,由于技术处理性是其特性之一,只有通过技术性处理才能得到生物识别信息,而技术处理则是从所采集的生物特征当中进行特征分析,形成相应的位置信息,并纳入至数据库保存。因此对于生物识别信息来说,其表现形式只有数据,而不像其他个人信息一般既有数据的形式,也有其他的表现形式比如纸质记载形式。因此在生物识别信息保护中,生物识别信息等同于生物识别数据,发挥识别性作用的是数据形式下所记载的特征位置信息,生物识别数据的概念只是对生物识别信息载体的再阐释,因此“生物识别数据”应当作为“生物识别信息”的下属概念。综上,笔者认为在应该以“生物识别信息”为统一表述。

如前文所述《生物特征识别信息的保护要求(征求意见稿)》已经对“生物识别信息”这一法律概念进行界定,但是由于将生物特征识别数据等同于生物识别信息,且并没有明确信息与数据之间的关系,造成了概念适用的混乱。数据与信息是载体与内容之间的关系,在生物识别信息保护领域,将数据等同于信息并无不妥,为了更好地区分生物识别信息与肖像权之间的界限,我们更应该着重强调生物识别信息的技术处理性。

123. 齐爱民,前注[2],第31-32页。

在大数据时代的今天，肖像、声音的很多表现形式也是数据，比如电子照片、电子录音录像数据，这些数据均含有生物特征有着识别性的作用甚至在生物识别技术的运用过程中也会产生这种相应的数据，但正如美国以及欧盟所规定的，美国将照片、录音排除出生物识别标识符的范围、而欧盟也不将对照片的处理当热认定为是对生物识别信息的处理，由此可见世界范围内，为了区分肖像权与生物识别信息，需要对部分的含有生物特征的数据排除出生物识别信息的范围，而是否采用技术处理就是区分肖像与生物识别信息的手段，而对于包含生物识别信息的视频、图片以及录音等数据则一般情况下将其排除出生物识别信息的范畴，只有采用技术性处理所生成的产物才可归类为生物识别信息。因此对明确生物识别信息的法律定义以及范围应该用以下几个方面进行规定：首先明确生物识别信息的来源与载体形式，生物识别信息是基于人体生物特征和行为特征为识别对象的数据；其次强调生物识别信息的技术处理属性，其实通过识别技术所生成的数据；再者明确生物识别信息的独特性与可识别性，即是能够指向单一自然人的，用于对自然人身份识别的能够指数据；最后通过不完全列举的方式，将现行的主流的生物识别信息明确比如人脸识别信息、指纹识别信息、声纹识别信息公示出来，并且通过举反例的方式，将包含生物特征的部分数据比如图片、健康信息以及录音等，排除出生物识别信息的范围，规定只有通过技术处理而得出可以识别自然人身份的生物特征信息的才属于生物识别信息。

综上所述，从法律层面上明确生物识别信息的法律概念，突出生物识别信息的技术处理性、独特性、可识别性，并且明确含有生物特征的个人信息与生物识别信息之间的区别，这为信息处理者的合规处理生物识别信息提供相应的指引，也给未来科技发展所诞生的更多的生物识别信息留出了法律保护的空间。

第二节 采用生物识别信息区分保护原则

《个人信息保护法》中对个人信息区分为一般个人信息与敏感个人信息，以及在信息处理者行为义务条款中规定信息处理者负有对个人信息负有实行分类管理的义务。¹²⁴由此可见个人信息分级分类的保护原则是《个人信息保护法》的全文贯彻的一个原则。

不少学者认识到了生物识别信息的特殊性，逐渐开始主张要求对生物识别信息进行

124. 《个人信息保护法》第五十一条第（二）项。

区分保护，设立特殊的处理规则。对生物识别信息的区分保护，除了将生物识别信息与一般个人信息进行区分保护，有的学者还主张对生物识别信息内部进行不同的区分保护。在学界中，部份学者所提出对生物识别信息进行区分保护的措施并不是基于生物识别信息本身，而是立足于信息主体，他们根据信息主体的不同，根据该类主体的职业特性、场景需求，而提出特殊的区分保护办法，学者们提出针对例如劳动者、雇员、运动员应该采取专门立法的保护模式。¹²⁵以信息主体为区分标准确实是实现生物识别信息区分保护的路径之一，但是以信息主体为区分标准仍有所欠缺随着社会的发展，社会分工会越来越细化，无论是普通的劳动者雇员，还是著名的运动员、演员等公众人物，在对他们的生物识别信息进行收集处理时总会需要进行特殊的规定，因此仅仅根据信息主体的性质作为生物识别信息的区分依据，则会导致生物识别信息民事保护规范的冗杂。纵观现行规范，无论是区分一般个人信息和敏感个人信息，又或者区分受到隐私权规范调整保护的私密信息还是个人信息，皆有区分的依据与标准，就是信息的敏感性与私密性。

张新宝教授认为敏感性等同于隐私性，提出在《个人信息保护法》中确立“个人敏感隐私信息”概念，主张“个人敏感隐私信息”信息属于个人隐私权的核心权利内容，具有高度私密性、对其公开或利用将会对个人造成重大影响。¹²⁶虽然《民法典》确立的个人私密信息的概念并纳入隐私权规范中，但《个人信息保护法》对敏感性的描述并没有突出私密性的特征，反而注重的是敏感信息的泄露对信息主体的侵权风险的评估。私密性通说是指个人所不希望披露且没有必要向公众披露的私人信息和事务以及私人空间和私人空间的自主决断，将私密性或者隐私性等同于敏感性，过于强调权利人的主观意志对私密信息的认定，会造成隐私权利的无限扩张，从而模糊隐私权和生物识别信息之间的界限。因此私密性与敏感性应当作为生物识别信息的区分标准，但这两个区分标准应该表示两个维度的内容。

生物识别信息因为与人身具有高度的依附性，其泄露会导致信息主体遭受相应的侵权风险，除了侵犯人格权益，还可能引发下游损害比如侵犯财产权等下游损害的发生，因此生物识别信息肯定皆属于敏感个人信息，但是不同类别的生物识别信息由于应用的范围、场景以及对信息主体的识别性程度的不同，也会导致生物识别信息之间的敏感性

125. 魏广萍：“劳动者生物识别信息的立法保护”，《工会理论研究（上海工会管理职业学院学报）》，2021年第6期，第40页；魏广萍，“雇员生物识别信息法律保护的主体性视角重构”，《科技与法律（中英文）》，2021年第5期，第72页；张鹏：“足球运动员生物识别信息保护：美国经验与中国策略”，《上海体育学院学报》，<https://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1005.G8.20220124.1539.003.html>，2022年1月26日，第39-40页。

126. 张新宝：“从隐私到个人信息：利益再衡量的理论与制度安排”，《中国法学》，2015年第3期，第50页。

存在差异。从《个人信息保护法》对敏感性的表述上看，立法者打算引入风险理论作为敏感性区分标准的理论基础。场景风险理论认为信息的敏感性并非一成不变，要视乎具体的应用场景对信息应用的风险进行动态的管理，因此敏感性的判断不能脱离于具体的应用场景。综上，笔者认为生物识别信息按照上述两种区分标准，采取区分保护的原则应该将生物识别信息区分为：个人敏感私密生物识别信息、个人敏感生物识别信息。

一、个人敏感私密生物识别信息

个人敏感私密生物识别信息即是指一般不会轻易曝光或者只会在特定场所下曝光，并且蕴含着信息主体希望不为他人知悉的典型的比如基因信息。基因识别信息作为生物识别信息虽然需要结合其他相关信息才可以对信息主体的身份进行识别，但往往会反映出信息主体的种族、身体状况、民族起源以及遗传病史，而上述这些蕴含的信息往往是信息主体所不愿被他人知悉，或者公开会造成影响信息主体生活安宁的信息，而且随着科技的发展，基因信息可以被编辑，这也是极大地危害了信息主体的健康与安全，甚至影响其代际权利。因此像基因信息这类别的生物识别信息，可以把他划分为个人敏感私密生物识别信息。而在民法典中对基因信息除了可以适用个人信息的相关规定，民法典也额外强调，从事基因信息有关的医学研究活动应该符合法定性、不得损害人体健康社会伦理和公共利益。个人敏感私密生物识别信息是个人信息与隐私权相交叉的民事权益。针对其处置规则，笔者认为应该采用最为严格的处理措施、保存手段。

二、个人敏感生物识别信息

个人敏感生物识别信息即是指多用于各种身份识别场景，信息的泄露会提升信息主体所遭受的风险。而之所以不认为个人敏感生物识别信息具有私密性是因为其本身就具有一定的公开性，能够为他人所知悉，不能隐藏。比如面部特征信息、声纹识别信息、掌纹识别信息、指纹识别信息以及大部分行为特征信息等。上述生物识别信息能被他人肉眼知悉因此不具有私密性，笔者不将其归类为私密敏感生物识别信息。但是正如上面所说由于场景风险理论，强调根据应用场景、以及风险泄露的程度进行判断，那么就意味着个人敏感信息内部进行可以根据敏感性进行划分，而笔者认为敏感性的标准的判定内涵就应该从能否应用场景多样性以及可识别程度进行划分。

（一）应用场景多可识别性高的个人敏感生物识别信息

该类生物识别信息作为敏感信息已经被广泛应用于各种身份识别场景，对自然人的身份有着直接的识别作用，可以单独或者与某一个人信息结合既能指明自然人的身份。而该类生物识别信息也被应用于各种场景，如金融领域一经泄露也会提高信息主体所遭受的侵权风险，比如面部特征识别信息、指纹识别信息、声纹识别信息等，从前文所列举的利用他人面部特征信息盗刷支付宝的案子，就能理解这类生物识别信息已经与自然人的日常生活紧密相连。

（二）应用场景少可识别性低的个人敏感生物识别信息

这类生物识别信息由于技术发展的不成熟，或者有着更便利的识别方式用以替代，又或者其自身的可识别性程度较低，必须与多类个人信息相结合才能指明自然人的身份比如步态行为特征信息，常出现于各种社会活动中，具有很强的公开性能被人肉眼所知悉或者被他人所听到，因此人们很少将其视为重要的生物识别信息，也很少用于“识别”、“安保”活动中。¹²⁷而笔迹特征信息作为另一类行为特征识别信息，虽然能起到识别身份的作用，但其属于间接识别，需通过笔迹对比并且结合其他识别信息才可识别他人身份。因此这类个人敏感生物识别信息相对来说敏感性较低。但是敏感性低不代表将该类生物识别信息排除出个人敏感信息，因为作为生物识别信息蕴含着相应人格利益与人格尊严，而且正如场景风险理论所蕴含的精神，敏感性是个动态发展的标准。

综上所述，按照私密性以及敏感性的区分标准，生物识别信息内部可以区分为两大类，即个人敏感私密生物识别信息以及个人敏感生物识别信息，而个人敏感生物识别信息内部仍可因为，因此对生物识别信息内部的处理规则上，也应当采取区分保护的原则。同一的处理规则，并不足以覆盖众多属性各异的生物识别信息，而最高法针对人脸识别信息单独出台一部相应的司法解释，也是看出了人脸识别信息在生物识别信息当中，作为敏感性程度较高的生物识别信息之一，目前需要特别的保护，因此从司法解释的视域下为人脸识别信息提供了特别保护。生物识别信息的处理规则包括对生物识别信息的收集、储存以及销毁等流程，引用区分保护原则，应该设立专门的条文保护，将生物识别信息的处理规则进行分级，应该在严格规定相应的处理规则。

127. 谢远扬：《个人信息的私法保护》，北京：中国法制出版社，2015年版，第93-94页。

第三节 完善生物识别信息的侵权救济制度

归责原则规范的冲突、损害结果的性质的认定不明，让生物识别信息的侵权救济制度在适用的过程中，发挥不到很好的保护效果。完善生物识别信息的侵权救济制度，如上文所述由于生物识别信息的特殊性，《民法典》和《个人信息保护法》对生物识别信息的分类目的以及分类的类别并不相同，导致生物识别信息在法律属性上与肖像权、隐私权和个人信息都有所联系，因此笔者支持将侵犯生物识别信息设立为特殊的侵权责任。

一、引入无过错责任归责原则

笔者认为将侵犯生物识别信息列为特殊侵权责任，并且针对侵犯生物识别信息的行为引入无过错责任归责原则，采取二元的归责原则更有助于保护生物识别信息。在《个人信息保护法（草案稿一）》对归责原则的确立是无过错责任归责原则，条文中规定信息处理者能证明无过错的，可以减轻责任。有学者认为，信息仅在交流时才具有意义，不能用于交流的内容不属于信息，对个人信息的保护也要防止对信息自由、言论自由等正当自由的不合理限制，对信息处理者强加过于严苛的责任也不利于未来信息技术的发展，并且个人信息作为一项民事利益，再者个人信息作为一项民事利益而并非一项权利，学者们认为相对于其他人格权利，赋予其严苛的归责原则并不符合法律体例上的一致性，因此在侵犯个人信息的归责原则上，并不支持适用严苛的无过错归责原则。《个人信息保护法》最终修改为统一适用过错推定归责原则。

从法律属性上看，生物识别信息作为个人信息的一项分类，在我国现行规范下的确并没有被视为一项独立的人格权，而是一项民事利益，但是对于权利与利益应当进行区分保护且利益受保护的程度应低于权利的观念来源于德国侵权法的权益区分理论，并且德国权益区分理论引入我国的背景在于我国并未像德国严格区分权利与利益的概念，为了防止权利的泛化，学界提出引入德国侵权法的权益区分理论。但这并不意味着权利的价值位阶一定比利益高，有学者认为权益区分理论只是针对权利和利益的保护在方法伦

上的区分。¹²⁸生物识别信息作为特殊敏感的个人信息，已经被《民法典》以及《个人信息保护法》出台相应的保护规定进行保护，虽然法律上并未将其升格为法律，但其业已成为法律明文规定的民事利益，正如方新军教授提出如果某种利益已经通过立法确认其受到法律保护，在保护的方式上与权利的保护并无本质的区别，甚至可能会出现利益比权利受到的保护程度更高的情形，¹²⁹因此并不能因为生物识别信息只是一项民事利益，而反对适用无过错归责原则。

从比较法的角度上，已经有其他国家或者地区针对信息侵权行为采用无过错责任原则，如上文所述，台湾地区的“个人资料保护法”是针对信息处理主体的不同，规定不同的处理规则，其规定公权力机关处理个人信息给信息主体造成损害的应当承担赔偿责任，虽然公权力机关处理个人信息给信息主体造成的损害所承担的是行政赔偿责任，但王泽鉴老师认为对与公务机关处理个人信息归责原则的相应规定具有侵权行为法的性质，当信息处理者是公务机关时采用的是无过错责任归责原则。¹³⁰除此之外还有匈牙利，在其颁布的《个人数据保护与公共利益数据公开法》第十八条就规定了无过错责任归责原则。匈牙利区分了数据控制者与数据处理者，并规定数据控制者对数据处理者的侵权行为承担无过错的替代责任。¹³¹由此可见在个人信息保护层面，严格责任归责原则是有实际适用的范例。

生物识别技术的运用规模运用场景日益增多，本质上生物识别技术仍属于一项新兴的科学技术，与网络服务技术的情景相类似。网络侵权责任是由于网络的大规模铺设而产生的一项特殊侵权责任，网络侵权责任具有高发性、损害后果严重性以及涉及第三方主体等特点，在网络侵权责任作为一项特殊的侵权责任，刚刚诞生时所适用的归责原则是无过错责任原则，¹³²如今的网络侵权责任适用的归责原则如上文所述是一般过错的归责原则。由此可见归责原则的适用并不是一成不变，对于发生在新兴领域的侵权行为，归责原则的适用经历着先严后松的适用过程，除非该侵权行为是具有危害他人人身安全高度风险的行为，那么会一直适用严格责任原则。而生物识别技术正处于一个这样的阶段，刚被大规模运用于社会场景中，对于侵犯生物识别信息的纠纷，信息主体并无太多

128. 刘承魁、刘磊：“论私密信息隐私权保护优先规则的困局与破解——以《民法典》第1034条第3款为中心”，《广东社会科学》，2022年第3期，第239-240页。

129. 方新军：《侵权责任利益保护的解释论》，北京：法律出版社，2021年版，第354页。

130. 王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京：北京大学出版社，2013年版，第248页。

131. 周汉华：《域外个人数据保护法汇编》，北京：法律出版社，2006年版，第210页。

132. 秦成德、危小波、葛伟，前注[72]，第270页。

的救济手段，而且生物识别信息一旦泄露则无法更改、无法复原的特性，也决定了信息主体更依赖于损害赔偿的救济手段，因此在现阶段生物识别信息的侵权行为的归责原则也可以适用无过错责任归责原则。

此外，生物识别信息适用无过错归责原则也有相应的理论基础，报偿理论是无过错责任的基础理论之一，报偿理论在危险责任以及替代责任中的含义也有所不同，在危险责任中法律允许个人为了经济或者自身利益的需要，实施具有潜在危险的行为比如使用物品、雇佣他人以及开办企业等行为，行为人在享受相应的危险行为所带来的利益的同时，也需要承担危险行为给他人造成损害的赔偿责任。¹³³而在替代责任的报偿理论认为，雇主或国家机关在享受其所雇佣的人员因履行职业所带来的利益，如果雇员在履行职责工作中给他人造成损害，需要其自身承担赔偿责任，对于雇员自身或者权益受损之人来说都是极度的不公平，对于权益受损之人来说，雇员的赔偿能力不及其雇主无法弥补其所受的损失，而雇员承担赔偿责任，也束缚了他们工作中的积极性。无论是危险责任的报偿理论，还是替代责任的报偿理论，其核心观点皆是“享受利益者”承担风险，生物识别技术作为一种新兴的识别技术，由于相对于其他的识别技术而言，对自然人身份的识别精确性高，降低使用者的识别成本，对于生物识别技术使用者而言是带来极大的相关利益，生物识别信息作为生物识别技术的产物，同时也是大数据时代下识别自然人身份的媒介，一旦泄露对于自然人来说，意味着其生物识别信息只能退出。并且生物识别信息的泄露并非只是危害一个自然人，而是会危害多个自然人，其危害结果是不可逆的，针对侵犯生物识别信息所带来的损害风险，就有学者主张将侵犯生物识别信息的责任承担方式纳入至《侵权责任法》高度危险责任一章中，¹³⁴而高度危险责任一章所适用的归责原则为无过错归责原则。因此生物识别信息侵权适用无过错归责原则有着充分的理论基础。如前文所述有的学者认为信息的价值在于交流，而笔者认为生物识别信息的识别作用，虽然本质是也是一种信息之间的交流，通过对生物特征的进行采集并转换成数据载体形式以识别身份就是一种信息交换，但正如前文所述，生物识别信息即是私益，又与公共利益紧密相连，虽然识别是一种交流，但并不等同于交流，其蕴含的核心是对身份安全的重视，因此侵犯生物识别信息的归责原则可以适用无过错归责原则。

133. [德] 克里斯蒂安·冯·巴尔：《欧洲比较侵权行为法》，张新宝译，北京：法律出版社，2004年版，第10页；转引自程啸，前注[47]，第127页。

134. 商希雪：“生物特征识别信息商业应用的中国立场与制度进路——鉴于欧美法律模式的比较评价”，《江西社会科学》，2020年第2期，第199页。

有学者主张引入无过错责任归责原则并与过错推定归责原则以及一般过错归责原则相结合,构建三元的归责原则体系,主张根据数据处理者的身份以及是否采用自动化处理数据考量归责原则的适用,其主张公务机关信息处理者应当适用无过错归责原则,而非公务机关信息处理者根据是否采用自动化决策手段处理数据而选择适用过错推定归责原则还是一般过错归责原则。¹³⁵笔者认为仅针对公务机关的信息处理行为引入无过错归责原则并不恰当,我国现行侵权责任规范中并不包含行政侵权责任,而公务机关的信息侵权行为应该交由行政法予以调整,相对于主要根据侵权行为人的不同而适用不同的归责原则,更应该根据侵权行为、侵权场景的不同以及生物识别信息的类别不同而适用不同的归责原则。如前文所述,生物识别信息的敏感性和私密性有所不同,针对应用场景较低可识别性低的敏感生物识别信息对其所实施一般的程序性违法的侵权行为,比如未获取信息主体同意、或者超出信息主体同意范围处理信息规范,以及其他违反个人信息保护规范处理生物识别信息的行为可以适用过错推定归责原则。而对于个人敏感私密生物识别信息以及应用场景多样可识别性高的个人敏感生物识别信息,所实施的侵权行为包括一般的程序性违法的侵权行为以及信息泄露的行为,以及应用场景较低可识别性低的敏感生物识别信息所实施的泄露行为,笔者认为针对信息处理者或者控制者可以适用无过错责任归责原则,由其向信息主体承担相应的赔偿责任后,可以向实际侵权人进行追偿。

二、完善生物识别信息侵权损害赔偿制度

关于人脸识别信息的司法解释以及《个人信息保护法》都对信息处理者的行为规范作出了相应的规定,并且《个人信息保护法》在敏感信息处理规则一节中,采用了引致性条款,将其他公法规范对信息处理者行为义务的规定也纳入进《个人信息保护法》的范围内。可以预见的是,未来信息处理者与信息主体之间的纠纷是主要是信息处理者不按照信息处理行为义务规范对个人信息进行处理,比如未经信息主体同意处理他人个人信息、或者未提供法律规定的必要保护措施但未造成实质损害的,而违反程序性的行为,在人脸识别的司法解释中明确为侵权行为。但是无论是人脸识别的司法解释还是《个人信息保护法》在关于损害赔偿的规定上都强调了实质性的损害,过于强调这并不利于信

135. 叶名怡:“个人信息的侵权法保护”,《法学研究》,2018年第4期,第93-95页。

息主体对其自身生物识别信息的保护,损害赔偿作为保护生物识别信息最为有效的一种责任承担方式,对于其完善,笔者认为可以从两个方面对侵犯生物识别信息的损害赔偿制度进行完善,分别是明确违反程序性的侵权行为损害认定标准以及对于侵犯生物识别信息的公益诉讼引入惩罚性赔偿制度。

(一) 明确“违反程序性侵权行为”的损害认定标准

在对违反程序性行为的规制上,有学者提议从可以从归责原则方面出发,通过使用过错推定的归责原则,通过举证责任的倒置,可以突破遭受“违反程序性行为”的侵权主体无法证明”损害“存在之困境。¹³⁶如今《个人信息保护法》的出台意味着在侵犯个人信息的归责原则已经适用过错推定归责原则,但是适用过错推定的归责原则并不意味着信息主体不需要承担证明损害的责任,在相关法律法规的规定下,针对精神损害的主张,法院仍需要其证明“严重”性。另外对于信息主体来说过错推定归责原则的设立,也不意味着其能当然适用损害赔偿责任进行救济,在我国赔礼道歉、排除妨害等也是责任承担方式之一,能在一定程度上慰藉信息主体的心灵,而司法实践中,法官也更乐于以赔礼道歉等人格权请求权方式替代损害赔偿请求权。但是但正如前文所论述的,由于生物识别信息的特殊性,一经泄露即是永久,不可索回,无法更改,而且生物识别信息作为敏感个人信息,一旦泄露,引发下游损害的风险相当明显因此前面所述的相应承担方式无法完全覆盖信息主体所遭受的损失,只有通过损害赔偿的责任承担方式,才能最大程度地弥补信息主体所遭受的损失。

明确“违反程序性侵权行为”的损害认定标准,笔者认为可以引入英美法系的行为自身可诉性侵权制度参考前文所提及的美国 *Rosenbach v. Six Flags* 一案,对于违法程序性的侵权行为,由于美国隐私权传统的可追偿性,美国法院认为只要实施了相应的违反隐私权规范的行为,即可推定权利人受到“委屈”(aggrieved),从而权利人无需证明实质损害的存在,美国的生物识别信息是纳入隐私权规范体系下,因此在该案中,法院无需信息主体证明其遭受损害。提倡引入英美法系行为自身可诉性侵权制度确立其中的原因之一就在于有效克服损害在客观上确实难以举证的侵权诉讼障碍。¹³⁷在我国针对生物识别信息的违反程序性的侵权行,在适用精神损害赔偿制度时,可以适时考虑生物识

136. 付微明,前注[25],第81页。

137. 胡雪梅,前注[114],第146页。

别信息的特殊性，对损害的认定标准不再要求严重精神损害，而是当相应的侵权行为发生时，即认可信息主体已遭受相应的精神损失，并且针对精神损害的赔偿数额，可以参照美国限定最高数额的损害赔偿制度，针对精神损害赔偿的数额设定上限，当信息主体有证据证明实际损失高于所设定的上限数额时，则依据实际损失。又或者转变传统的损害观念及其认定标准，针对侵犯生物识别信息的损害不再要求“确定性”标准，引入风险观念，承认风险在一定程度上可转变为损害。¹³⁸

（二）明确侵犯生物识别信息民事公益诉讼适用惩罚性损害赔偿制度

《个人信息保护法》规定了人民检察院、由法律授权的消费者组织以及国家网信部门确定的确定的组织可以依法提起公益诉讼，但是个人信息公益诉讼能否适用惩罚性损害赔偿制度却没有明示确定。惩罚性损害赔偿制度起源于英国，惩罚性损害赔偿的目的除了填平受害人所遭受的损失，更重要的是对侵权行为人起到惩戒与威慑的作用。惩罚性损害赔偿的适用具有法定性，如果法律没有明文规定，受害人并不能提起惩罚性损害赔偿请求。对公益诉讼适用惩罚性赔偿制持否定态度的学者认为，应该坚持惩罚性赔偿的法定性，王利明教授认为从文义解释的角度，适用惩罚性赔偿的主体是被侵权人，而公益诉讼的主体并不具有被侵权人的身份，从体系解释的角度上看，关于惩罚性赔偿的条文规定被设立于民事公益诉讼的条文规定之前，因此公益诉讼不应该适用惩罚性赔偿制度。¹³⁹而张新宝教授也认为个人信息保护公益诉讼的惩罚性赔偿并没有法律上的依据，我国惩罚性赔偿制度的设立仅针对私益诉讼，且会带来对被告罚过其当，不利于数据保护与平衡的不利后果等不利后果。¹⁴⁰而持肯定说的学者们则基于惩罚性赔偿的威慑作用，结合个人信息侵权行为的主观恶性大、获利高、所带来的损害较大等特点，认为补偿性损害赔偿责任不能填补被害人的损失，且无法对信息侵权行为起到相应的规制作用，因而应该适用惩罚性赔偿制度。¹⁴¹

如前文所述，区分保护是对个人信息的一种保护手段，依据不同类别的个人信息设置不同的处置手段是《个人信息保护法》所给我们带来的直观感受。针对所有类别的个

138. 田野，前注[109]，第38-39页；谢鸿飞，前注[93]，第35-36页。

139. 王利明：“《民法典》中环境污染和生态破坏责任的亮点”，《广东社会科学》，2021年第1期，第221页。

140. 张新宝：“个人信息保护公益诉讼制度的理解与适用”，《国家检察官学院学报》，2021年第5期，第69-71页。

141. 薛天涵：“个人信息保护公益诉讼制度的法理展开”，《法律适用》，2021年第8期，第164页；孙传玺、崔雪：“侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件难点破解”，《中国检察官》，2020年第14期，第69页。

人信息公益诉讼不加区分地适用惩罚性赔偿制度，的确会不利于数据的保护与利用，因此笔者仅主张针对侵犯生物识别信息的行为采用惩罚性赔偿的制度。个人信息侵权行为具有无接触性、隐蔽性以及规模性等特点，而生物识别信息由于其特殊性，一旦发生生物识别信息侵权行为，那么信息主体很难将自身生物识别信息的利益状态恢复至圆满，而最直观的后果就是以生物识别信息为核心的数字身份无法在安全的情况下发挥识别作用。通过前文我国司法案例的梳理，我们可以发现对于信息侵权案件，法院所支持的损害赔偿金额相对于信息处理主体所能获得的利益而言实属杯水车薪，而对于精神损害赔偿的严苛要求，也让信息主体希冀通过精神损害赔偿予以救济的路径无法实现。相对于金钱上的补偿，我国司法实践更多是支持以赔礼道歉作为信息侵权的主要责任承担方式，用以慰藉信息主体。但是正如生物识别信息的技术处理性，让一般的个人不易成为生物识别信息侵权行为人，而企业则会因为生物识别信息的载体所展现出来的巨大经济价值成为主要的侵权主体，那对于企业来说仅仅是赔礼道歉或者几千元的现金赔偿并不能很好的起到预防作用。因此针对生物识别信息的民事公益诉讼应该从立法上明确适用惩罚性赔偿。

再者，在司法实践中已经有已经有个人信息侵权适用惩罚性赔偿的先例。“河北省保定市人民检察院诉李某侵害公民个人信息民事公益诉讼案”被称为信息侵权公益诉讼惩罚性赔偿第一案，该案判决的作出是在《个人信息保护法》出台前，李某利用非法收集的个人信息进行广告宣传以及促销活动，而检察院发现其促销活动构成消费欺诈而提起惩罚性赔偿诉讼。虽然该案惩罚性赔偿的请求权基础来源于消费者保护相关法律，但有学者据此主张《个人信息保护法》明确信息侵权公益诉讼适用惩罚性赔偿，但正如前文所列举的反对观点，最终《个人信息保护法》也未能明确规定适用惩罚性赔偿。

笔者认为针对信息侵权适用惩罚性赔偿的否定观点并不能类推得出生物识别信息侵权不适宜采用惩罚性赔偿制度的结论。首先生物识别信息的特殊性则要求其需要相比于个人信息更为严苛的的保护措施，基于信息保护与利益衡平的考量可以只针对侵犯生物识别信息的侵权活动，适用惩罚性赔偿制度，而其他类别个人信息公益诉讼则可以排除惩罚性赔偿制度，并且根据。其次从惩罚性赔偿请求权基础来源进行区分，已经有学者认为我国的惩罚性赔偿不再仅针对私益诉讼，并呼吁立法机关在私人惩罚性赔偿请求权之外专门为检察机关社会团体设立的惩罚性赔偿请求权。黄忠顺教授则认为现行法阙下根据诉讼信托理论，公益诉讼的主体可以以自身名义提起惩罚性损害赔偿请求，但

由于使依附型惩罚性赔偿请求权面临诸多困境，且司法实践中也未发生相应案例，面临越来越多的公益诉讼适用惩罚性赔偿制度的案例，其主张通过立法设立独立性的惩罚性损害赔偿请求权。¹⁴²杨会新老师分析了消费的公益诉讼司法现状，总结出消费公益诉讼惩罚性赔偿的行使有两种模式：一种是集中行使模式，一种则是新设权利模式。¹⁴³而集中行使模式的惩罚性赔偿其实就是检察机关通过对替代私人惩罚性赔偿请求权人进行集中行使的一种模式。因此从立法论针对生物识别信息的公益诉讼通过立法明确适用惩罚性赔偿，可以与个人信息侵权公益诉讼进行区分，通过对信息侵权公益诉讼惩罚性赔偿适用范围的限缩，起到保持维护数据利用与数据保护衡平的作用的同时，也能保持对信息处理者的威慑和惩治。

142. 黄忠顺：“惩罚性赔偿消费公益诉讼研究”，《中国法学》，2020年第1期，第267页，第272页。

143. 杨会新：“公益诉讼惩罚性赔偿问题研究”，《比较法研究》，2021年第4期，第116-117页。

结语

法律的滞后性一直是权益保护不可避免的问题，在如今技术快速发展的年代，科学技术从理论转换为实际应用的时间间隔正在缩短，许多以往未被发现或者未被纳入民事规范保护范围的客体逐渐涌现。在此背景下法律的滞后性愈发明显。《民法典》以及《个人信息保护法》的颁布让生物识别信息受到相应的规范保护，但是粗放式的立法，宏观而模糊的法律描述，让相应的保护规范忽略了生物识别信息的特殊性。生物识别信息与个人私益息息相关，蕴含着人格尊严与人格自由，同样由于其应用场景也让生物识别信息与公共利益紧密相连。

《个人信息保护法》的出台意味着我国个人信息保护采用了综合保护模式，但是《个人信息保护法》规范描述宏观模糊，并不能很好地保护生物识别信息，生物识别信息的特殊性是个人信息保护规范不可避免的问题，虽然从个人信息层面设立了删除更改查阅等权能以增强信息主体对生物识别信息的支配控制，但生物识别信息的特殊性决定了删除更改等权能无法起到应有的保护作用，而生物识别信息法律概念的模糊，也会让现行规范无法尽可能涵盖所有生物识别信息。而尚未意识到生物识别信息的特殊性，也是采用概况规范的方式保护生物识别信息的原因之一，而这也导致了损害认定标准与其他个人信息相一致，要求有实质的财产损害或者严重的精神损害，而这损害认定标准无助于对违反程序性侵权行为进行相应的规制。

生物识别信息作为大数据时代数字身份的核心，其高度的人身依附性让其客体蕴含着人格尊严与人格自由，如果无法针对生物识别信息的特殊性设立相应的保护规范，那么危害的是权利人的尊严与人格自由，以及与生物识别信息息息相关的其他权益。明确生物识别信息的一般概念，列明生物识别信息的类别，有助于设立规范的保护范围，提高企业处理生物识别信息的可预见性。而对生物识别信息的区分保护原则应当贯穿于个人信息的保护规范，针对生物识别信息的特殊性设立相应的分类保护制度。生物识别信息区分保护原则在侵权责任法领域的体现，即是应该将侵犯生物识别信息列为特殊的侵权责任，根据侵权行为的不同适用不同的归责原则，并且针对违反程序性的行为应当降低对损害的认定标准。

致谢

当我如释重负地敲下本篇论文的最后一个字符，这也意味着三年的硕士研究生学习生涯已经接近尾声。虽然远离家乡异地求学，但也没让我感觉时光漫长，时间总是在不经意间从我们的指尖悄悄流逝。接近三年的求学时光如同电影一样，一幕幕的在我脑海中闪映。首先感谢的是我的父母，俗话说家是最温暖的港湾，他们在我本科毕业工作后，仍支持我辞职求学深造，为我的求学之路提供了物质上以及精神上的支持，他们通过对我的日常生活的嘘寒问暖，通过对我的学习生活的事事关心，来表达他们对我的支持。正因为他们不遗余力的支持，支撑着我对探索知识的渴望。他们的支持却从来不求回报，我的父母他们一直是我强大而坚硬的后盾。三年的时间说长不长，却也足以在父母的容貌上烙上时光的印记，望着父母头上尽教添白发，衷心地希望时间的流逝能慢一些，让我能够尽自己所能报答父母对我的恩情。

其次需要感谢的是我的导师杜明强老师，我导作为一名年青导师，在日常生活中与我们相处融洽。学习上，科研教学工作繁忙的他仍然不忘严格要求我的毕业论文。导师在论文指导方面给予了我很大的帮助，不论是论文结构还是写作思路，都给予了我们极大的建议，每当对论文没有相应的写作思路时，是老师的指导，让我找到了写作的思路，也是老师每个学期组织的组会，督促我们学习，让我的学术素养慢慢积累。

再者需要感谢的还有跟我同宿舍的 18 级法律法学的师兄们，以及我的同班同学们，是他们的存在让我的硕士研究生生活变得更加丰富多彩，18 级的师兄们让我更快地适应了硕士研究生的生活，给予了很多的学习上生活上的经验，而我的同学们来自天南地北，但大家之间的相处宛如家人。最后需要感谢的是我的本科母校与硕士母校，本科四年打下了坚实的专业基础，而硕士三年的深研经历，也让我获益良多。没有母校提供的平台也没有如今的我，良师益友，韦编三绝，是我三年研究生生活的最大收获，希望大家在未来的生活一帆风顺。

参考文献

一、中文文献

(一) 著作类

1. 王利明：《人格权法（第二版）》，北京：中国人民大学出版社 2015 年版。
2. 王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京：北京大学出版社，2013 年版。
3. 秦成德，危小波，葛伟：《网络个人信息保护研究》，西安：西安交大出版社，2016 年版。
4. 郭锐：《人工智能的伦理和治理》，北京：法律出版社，2020 年版。
5. 周雪峰、蔡雄山主编：《网络空间法治化的全球视野与中国实践》，北京：法律出版社，2019 年版。
6. 程啸：《侵权责任法（第三版）》，北京：法律出版社，2021 年版。
7. [德]罗伯特·海因德尔：《世界指纹史》，刘持平、何海龙、王京译，北京：中国人民大学出版社，2013 年版。
8. 姚秋英：《人格权研究》，北京：中国政法大学出版社，2012 年版。
9. 沈中、许文洁：《隐私权论兼析人格权》，上海：上海人民出版社，2010 年版。
10. 祝恩、殷建平、张国敏等：《自动指纹识别技术》，长沙：国防科技大学出版社，2006 年版。
11. 谢远扬：《个人信息的私法保护》，北京：中国法制出版社，2015 年版。
12. 周汉华：《域外个人数据保护法汇编》，北京：法律出版社，2006 年版。
13. 方新军：《侵权责任利益保护的解释论》，北京：法律出版社，2021 年版。

(二) 论文类

14. 王利明：“论个人信息权在人格权法中的地位”，《苏州大学学报（哲学社会科学版）》，2012 年第 6 期。
15. 程啸：“民法典编纂视野下的个人信息保护”，《中国法学》，2019 年第 4 期。
16. 高富平：“论个人信息保护的目的一——以个人信息保护法益区分为核心”，《法商研究》，2019 年第 1 期。
17. 朱巍：“人脸识别的法律性质认定”，《检察日报》，2019 年 11 月 6 日，第七版。
18. 王禄生：“论‘深度伪造’智能技术的一体化规制——从‘杨幂换脸视频’谈起”，《东方法学》，2019 年 12 月 2 日，<https://doi.org/10.19404/j.cnki.dffx.20191029.001>。
19. 邢会强：“人脸识别的法律规制”，《比较法研究》，2020 年第 5 期。
20. 洪延青：“人脸识别技术的法律规制研究初探”，《中国信息安全》，2019 年第 8 期。
21. 曹建峰：“深度伪造技术的法律挑战及应对”，《信息安全与通信保密》，2019 年第 10 期。
22. 张红：“指纹隐私保护：公、私法二元维度”，《法学评论》，2015 年第 1 期。
23. 张建文：“指纹资料隐私保护的基本思考——以港澳台地区指纹资料隐私保护为视角”，《兰州学刊》，2011 年第 3 期。
24. 姚岳绒：“身份证取得时强制性采集指纹行为的宪法分析”，《法学》，2012 年第 5 期。
25. 付微明：“大数据时代个人生物识别信息法律保护的重要意义”，《研究生法学》，2019 年第 34 卷第 4 期。
26. 付微明：“个人生物识别信息的法律保护模式与中国选择”，《华东政法大学学报》，2019 年第 6 期。
27. 付微明：“个人生物识别信息民事权利诉讼救济问题研究”，《法学杂志》，2020 年第 3 期。
28. 赵精武：“《民法典》视野下人脸识别信息的权益归属与保护路径”，《北京航空航天大学学报（社会科学版）》，2020 年第 5 期。
29. 范为：“大数据时代个人信息保护的路径重构”，《环球法律评论》，2016 年第 5 期。

30. 田野：“大数据时代知情同意原则的困境与出路——以生物资料库的个人信息保护为例”，《法制与社会发展》，2018年第6期。
31. 田野：“风险作为损害：大数据时代侵权‘损害’概念的革新”，《政治与法律》，2021年第10期。
32. 周汉华：“个人信息保护的法律定位”，《法商研究》，2020年第3期。
33. 冉克平：“论个人生物识别信息及其法律保护”，《社会科学辑刊》，2020年第6期。
34. 齐爱民：“论个人信息的法律保护”，《苏州大学学报》，2005年第2期。
35. 王利明：“论个人信息权的法律保护——以个人信息权与隐私权的界分为中心”，《现代法学》，2013年第4期。
36. 王利明：“《民法典》中环境污染和生态破坏责任的亮点”，《广东社会科学》，2021年第1期。
37. 刘越：“论生物识别信息的财产权保护”，《法商研究》，2016年第6期。
38. 王叶刚：“论网络隐私政策的效力——以个人信息保护为中心”，《比较法研究》，2020年第1期。
39. 潘林青：“面部特征信息法律保护的技术诱因、理论基础及其规范构造”，《西北民族大学学报（哲学社会科学版）》，2020年第6期。
40. 蒋洁：“人脸识别技术应用的侵权风险与控制策略”，《图书与情报》，2019年第5期。
41. 朱工宇：“生物识别与隐私权保护之法律冲突及其协调”，《科技与法律》，2009年第6期。
42. 商希雪：“生物特征识别信息商业应用的中国立场与制度进路——鉴于欧美法律模式的比较评价”，《江西社会科学》，2020年第2期。
43. 王德政：“针对生物识别信息的刑法保护：现实境遇与完善路径——以四川“人脸识别案”为切入点”，《重庆大学学报（社会科学版）》，2020年4月8日，<http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.c.20200407.1725.006.html>。
44. 徐同祥、李宇：“中国指纹技术的起源及其早期应用”，《江苏警官学院学报》，2012年3月。
45. 邢会强：“大数据交易背景下个人信息财产权的分配与实现机制”，《法学评论》，2019年第6期。
46. 郑方、艾斯卡尔·肉孜、王仁宇等：“生物特征识别技术综述”，《信息安全研究》，2016年第1期。
47. 孙哲男、赫然、王亮等：“生物特征识别学科发展报告”，《中国图像图形学报》，2021年第6期。
48. 刘乐、陈伟、张济国等：“声纹识别：一种无需接触、不惧遮挡的身份认证方式”，《中国安全防范技术与应用》，2020年第1期。
49. 朱应钊、李嫚：“步态识别现状及发展趋势”，《电信科学》，2020年第8期。
50. 曾昌：“分离困境与整合路径：大数据时代下个人生物识别信息保护制度之完善”，《云南社会科学》，2021年9月2日，<https://kns.cnki.net/kcms/detail/53.1001.C.20210831.1730.030.html>。
51. 谢鸿飞：“个人信息泄露侵权责任构成中的‘损害’——兼论风险社会中损害的观念化”，《国家检察官学院学报》，2021年第5期。
52. 张继红、文露：“美国《加州隐私权法案》评述”，《中国信息安全》，2021年第3期。
53. 陆海娜、赵赓：“个人生物识别信息商业利用的法律规制：美国州立法经验的比较与反思”，《人权研究》，2021年第2期。
54. 郭如愿：“大数据时代个人信息商业利用路径研究——基于个人信息财产权的理论检视”，《科技与法律》，2020年第5期。
55. 胡雪梅：“英美侵权法行为‘自身可诉’侵权制度及其合理借鉴——以我国侵权责任法的完善为中心”，《现代法学》，2011年第1期。

56. 刘承魁、刘磊：“论私密信息隐私权保护优先规则的 困局与破解 ——以《民法典》第 1034 条第 3 款为中心”，《广东社会科学》，2022 年第 3 期。
57. 叶名怡：“个人信息的侵权法保护”，《法学研究》，2018 年第 4 期。
58. 薛天涵：“个人信息保护公益诉讼制度的法理展开”，《法律适用》，2021 年第 8 期。
59. 黄忠顺：“惩罚性赔偿消费公益诉讼研究”，《中国法学》，2020 年第 1 期。
60. 刘德良：“个人信息保护立法应明确人格权和财产权属性”，《中国信息安全》，2015 年第 5 期。
61. 魏广萍：“劳动者生物识别信息的立法保护”，《工会理论研究（上海工会管理职业学院学报）》，2021 年第 6 期。
62. 魏广萍，“雇员生物识别信息法律保护的主体性视角重构”，《科技与法律（中英文）》，2021 年第 5 期。
63. 张鹏：“足球运动员生物识别信息保护：美国经验与中国策略”，《上海体育学院学报》，2022 年 1 月 26 日，<https://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1005.G8.20220124.1539.003.html>。
64. 张新宝：“个人信息保护公益诉讼制度的法理展开”，《法律适用》，2021 年第 8 期。
65. 张新宝：“从隐私到个人信息：利益在衡量的理论与制度安排”，《中国法学》，2015 年第 3 期。
66. 杨会新：“公益诉讼惩罚性赔偿问题研究”，《比较法研究》，2021 年第 4 期。
67. 孙传玺、崔雪：“侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件难点破解”，《中国检察官》，2020 年第 14 期。
- （三）其他类
68. 香港个人资料私隐公署：《收集及使用生物辨识资料指引》，2020 年 8 月，https://www.pd.org.hk/tc_chi/resources_centre/publications/files/GN_biometric_c.pdf。
69. 前瞻产业研究院：“2020 全球生物识别行业市场现状与发展趋势分析 非接触式识别将得以大量应用”，前瞻网，2020 年 12 月 31 日，<https://www.qianzhan.com/analyst/detail/220/201204-e37f7829.html>。
70. 《澳门个人资料法》，2005 年 8 月 4 日，<https://www.al.gov.mo/uploads/attachment/2019-03/806185c8245bd74eba.pdf>。
71. 牛谷月：“Facebook 因侵犯隐私向 160 万用户赔偿 6.5 亿美元 专家：人脸识别边界划分要靠法律”，央广网，2021 年 3 月 4 日，http://finance.cnr.cn/2014jingji/djbd/20210304/t20210304_525427264.shtml。
72. “三星被曝屏下指纹存在安全漏洞 罪魁祸首是手机保护膜”，腾讯网，2021 年 6 月 30 日，<https://new.qq.com/omn/20191016/20191016A03CRU00.html>。
73. 苏晓：“售楼处人脸识别背后的‘暗战’”，中房网，2020 年 12 月 3 日，<http://www.fangchan.com/news/320/2020-12-03/6740110509972198108.html>。
74. 陈志芳：“数说：AI 换脸色情视频祸害了谁？韩国女偶像深受其害”，腾讯网，2021 年 6 月 30 日，<https://new.qq.com/omn/20191016/20191016A0IOU700.html>。
75. 朱芸阳：《「脸」的三重内涵及其法律规制》，2019 年 11 月 8 日，虎嗅网，<https://huxiu.com/article/325308.html>。
- 二、外文文献
- 论文类
76. Els Kindt,“Biometric applications and the data protection legislation,”*Datenschutz und Datensicherheit*,vol.31,no.3,2007.
77. Hannah Zimmerman,“The Data of You:Regulating Private Industry's Collection of Biometric Information,”*Kansas Law Review*, vol. 66, February 2018.
78. Ioannis Iglezakis,“EU data protection legislation and case-law with regard to biometric applications,”*Social Science Electronic Publishing*, January 2013.
79. Jan Grijpink,“Anassessment model for the use of biometrics,”*Computer Law & Security Review*,vol.22,no.4,March 2006.
80. Justin Kay and Brendan McHugh,“The Next Steps for Biometrics Legislation Across US,”*LAW360*, May 2017.

